חוברת 1 · סיכום מלא

משפט חוקתי

הסיכום המקיף

מושגים, סעיפי חוק, פסקי דין, טבלאות השוואה וטיפים למבחן

19 פרקים

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

סיכום לפי פרקים

1 מבוא למשפט חוקתי

2 המהפכה החוקתית

3 מעמד חוקי היסוד ושריון

4 פסקת ההגבלה

5 פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

6 ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

7 ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

8 זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

9 זכויות מנויות ובלתי מנויות

10 פסילת מפלגות

11 חסינות חברי כנסת

12 הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

13 הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

14 חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

15 חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

16 חופש הדת והחופש מדת

17 זכויות חברתיות

18 מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

19 חופש העיסוק

פרק 1

מבוא למשפט חוקתי

1.1 מהו משפט חוקתי ולמה הוא חשוב

המשפט החוקתי הוא ענף של המשפט הציבורי. הוא עוסק בשתי שאלות יסוד: **איך בנוי השלטון** (מה סמכויותיהן של הכנסת, הממשלה ובתי המשפט, ומה היחס ביניהן), ו**אילו זכויות יש לאדם מול השלטון** (ומתי מותר לשלטון לפגוע בהן). בניגוד למשפט הפרטי, שמסדיר יחסים בין שווים, המשפט החוקתי מסדיר ומגביל את הכוח של המדינה עצמה. לכן הוא נושא הליבה של כל המשפט הציבורי, ובלעדיו אי אפשר להבין את המנהלי, הפלילי והאזרחי.

✦ הגדרה — חוקה

מסמך-על המסדיר את מבנה הרשויות ואת זכויות היסוד, ועומד **מעל** החקיקה הרגילה. חוק רגיל הסותר אותו - בטל. חוקה **פורמלית** היא מסמך כתוב ואחיד שנחקק בהליך מיוחד. חוקה **חומרית** היא מכלול הנורמות שמסדירות בפועל את המשטר, גם אם הן מפוזרות בכמה מקורות.

1.2 שלושת מאפייני החוקה

1. **עליונות נורמטיבית** - החוקה גוברת על חוק רגיל.
2. **נוקשות (שריון)** - קשה יותר לשנותה מאשר חוק רגיל, כדי להגן מפני רוב מזדמן.
3. **ביקורת שיפוטית** - גוף שיפוטי מוסמך לבדוק אם חוק רגיל עומד בחוקה, ולפסול אותו אם לא.

מכאן נגזר גם הקשר ל**דמוקרטיה**: דמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. דמוקרטיה מהותית מגבילה גם את הרוב כדי למנוע "עריצות הרוב" ולהגן על המיעוט ועל זכויות הפרט. חוקה והביקורת השיפוטית הן הכלים להגבלה זו, והמתח בין הכרעת הרוב להגנה על זכויות עובר כחוט השני לאורך כל הקורס.

1.3 הרקע ההיסטורי: למה אין לישראל חוקה שלמה

מגילת העצמאות (1948) הבטיחה שחוקה תיקבע עד 1 באוקטובר 1948, אך הדבר לא קרה. הסיבות: מחלוקות עמוקות בין חילונים לדתיים על אופי המדינה, רצון להימנע מהכרעות שנויות במחלוקת בימי המלחמה והקמת המדינה, והעדפה של שלטון הרוב הפרלמנטרי. בשנת 1950 התקבלה **החלטת הררי**: הכנסת תכין חוקה פרק אחר פרק, כשכל פרק יהיה "חוק יסוד", ובסופו של דבר כל הפרקים יצטרפו לחוקה אחת. בפועל הפרקים נחקקו לאורך עשרות שנים, והחוקה מעולם לא נחתמה כמסמך אחד.

§ סעיף — חוקי היסוד

החוק הראשון, חוק יסוד: הכנסת, נחקק ב-1958. מאז נחקקו חוקי יסוד בנושאי הנשיא, הממשלה, הצבא, ירושלים, מקרקעי ישראל, כלכלת המדינה, השפיטה, מבקר המדינה, משאל עם וחוק הלאום, וכן שני חוקי הזכויות מ-1992: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק.

1.4 ממודל ווסטמינסטר למודל חוקתי

	עליונות הפרלמנט (ווסטמינסטר)	עליונות החוקה
מי הריבון	הפרלמנט, בלי הגבלה	החוקה, והפרלמנט כפוף לה
מעמד חוק רגיל	תקף תמיד כל עוד חוקק כדין	בטל אם הוא סותר את החוקה
ביקורת שיפוטית על חקיקה	אין	יש
דוגמה	בריטניה (בעבר)	ארצות הברית, ישראל לאחר 1995

עד שנות התשעים נחשבה ישראל לדוגמה למודל הראשון: הכנסת יכלה לחוקק כל חוק, ובית המשפט יכול היה רק לפרש אותו ולבקר את הרשות המבצעת. השינוי הדרמטי הגיע בשנת 1992 עם חקיקת שני חוקי היסוד על זכויות האדם, וקיבל את אישורו השיפוטי ב-1995 בפסק דין בנק המזרחי.

⚖ פסק דין — בנק המזרחי המאוחד נ׳ מגדל כפר שיתופי (1995)

בנקים תקפו את "חוק גל" להסדר חובות חקלאים בטענה לפגיעה בקניין. בית המשפט העליון, בהרכב מורחב, קבע שחוקי היסוד הם בעלי מעמד על-חוקי, ושבית המשפט מוסמך לפסול חוק רגיל הסותר אותם שלא כדין. בפועל נדחתה העתירה, כי הפגיעה עמדה בפסקת ההגבלה. הנשיא ברק כינה זאת "המהפכה החוקתית" (נדון בפרק הבא).

1.5 תקדימים מוקדמים של ביקורת שיפוטית וזכויות

- **קול העם (1953)** - הגנה על חופש הביטוי בדרך פרשנות, לפני שהיה לו עיגון חוקתי.
- **ברגמן (1969)** - חוק מימון מפלגות שפגע בשוויון הבחירות ללא הרוב הנדרש בחוק יסוד: הכנסת נפסל. זה היה ביטוי מוקדם לכוחה של הוראה משוריינת.
- **רסלר (1988)** - הרחבת זכות העמידה ושפיטות העניינים הציבוריים, והבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית.

⚖ פסק דין — ברגמן נ׳ שר האוצר (בג"ץ 98/69)

חוק מימון מפלגות העדיף מפלגות קיימות על פני חדשות, ונתקבל ברוב פשוט, אף שס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת, המעגן שוויון בבחירות, משוריין ברוב של חברי הכנסת. בית המשפט קבע שהוראת השריון מחייבת את הכנסת, וחוק שנחקק בניגוד לה אינו תקף. הדגשה למבחן: זה סירוב לשינוי "בדלת האחורית".

1.6 שלד לפתרון שאלה חוקתית

1. זהה את **מקור הנורמה**: חוק רגיל, חוק יסוד, החלטה מנהלית.

2. בדוק אם יש **חוק יסוד רלוונטי** ומה מעמדו (שריון?).
3. אם נפגעה **זכות** - עבור לפסקת ההגבלה (פרק 4).
4. אם נבחנת **תקינות ההליך** - ראה פרקים 6-7.
5. סיים בסעד: ביטול, בטלות מושהית, פרשנות מקיימת, או דחיית העתירה.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לבלבל בין חוקה **פורמלית** (מסמך אחד) לבין **חוקה חומרית** - בישראל קיימת רק השנייה.
- לומר שבנק המזרחי יצר את הביקורת השיפוטית כבר ב-1995 "יש מאין" - בפועל התקדימים (כמו ברגמן) קדמו לו; החידוש הוא ההכרה בעליונות כללית.
- לחשוב שהחלטת הררי כתבה חוקה - היא רק קבעה דרך: חוקה פרק אחר פרק.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

הכנסת חוקקה ברוב רגיל חוק שמבטל את חובת השוויון בבחירות, והוראת שוויון זו משוריינת בחוק יסוד: הכנסת. **פתרון:** לפי ברגמן, הוראה משוריינת חייבת לעמוד ברוב הנדרש; ללא הרוב המיוחד החוק בטל או חסר תוקף. התשובה אינה תלויה בשאלה אם החוק "הוגן" אלא בהליך ובמעמד הנורמטיבי.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- משפט חוקתי = מבנה השלטון + זכויות יסוד מול השלטון.
- חוקה: עליונות, נוקשות, ביקורת שיפוטית.
- אין חוקה אחת בישראל; החלטת הררי (1950) הוליכה לחוקי יסוד.
- 1992: חוקי הזכויות. 1995: בנק המזרחי קבע עליונות חוקי היסוד.
- תקדימי עבר: קול העם (1953), ברגמן (1969), רסלר (1988).

פרק 2

המהפכה החוקתית

2.1 מה קרה ב-1992 ולמה זו "מהפכה"

במרץ 1992 חוקקה הכנסת שני חוקי יסוד שעניינם זכויות אדם: **חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** ו**חוק יסוד: חופש העיסוק** (שנחקק מחדש ב-1994 עם פסקת התגברות). לראשונה נכללו בחקיקה ישראלית זכויות יסוד לצד **פסקת הגבלה**, כלומר נוסחה המגדירה מתי מותר לפגוע בהן. במשך שנים לא הייתה ברורה משמעות החקיקה, עד שבית המשפט העליון קבע בשנת 1995, בפסק דין בנק המזרחי, שיש לה מעמד על-חוקי. הנשיא ברק כינה את השינוי "המהפכה החוקתית": ישראל עברה מעליונות הכנסת לעליונות החוקה.

⚖ פסק דין — בנק המזרחי המאוחד נ׳ מגדל כפר שיתופי (1995)

בנקים ובעלי נכסים תקפו את "חוק גל", שהסדיר את חובות המגזר החקלאי ופגע, לטענתם, בקניין הנושים. ההרכב המורחב (תשעה שופטים) קבע שחוקי היסוד הם בעלי מעמד חוקתי עליון, ושבית המשפט רשאי לפסול חוק רגיל שסותר אותם. העתירה נדחתה, כי הפגיעה בקניין עמדה בתנאי פסקת ההגבלה. מכאן נולד המבחן החוקתי בישראל.

2.2 תורת שני הכובעים: מקור העליונות

הבעיה המשפטית: חוק יסוד נחקק לרוב באותו הליך, ובאותו רוב, כמו חוק רגיל. מנין העליונות? תשובתו של ברק היא **תורת הסמכות המכוננת**: הכנסת חובשת שני כובעים. כאשר היא מחוקקת חוק יסוד, היא פועלת כ**רשות מכוננת** (יוצרת חוקה), וכאשר היא מחוקקת חוק רגיל, היא פועלת כ**רשות מחוקקת**. נורמה שנוצרה בכובע המכונן גוברת על נורמה שנוצרה בכובע המחוקק, בדיוק כפי שחוקה גוברת על חוק.

הסמכות המכוננת מבוססת על כך שהכנסת הראשונה נבחרה גם כדי לנסח חוקה, והיא עברה ממנה לכנסות הבאות.

> **✦ הגדרה — סמכות מכוננת**
>
> הסמכות ליצור חוקה ולתקן אותה. לפי ברק, היא נתונה לכנסת כשהיא מחוקקת "חוק יסוד", ושונה במהותה מהסמכות לחוקק חוק רגיל.

2.3 שלוש הגישות בבנק המזרחי

שופט	עיקר הגישה
הנשיא ברק	יש סמכות מכוננת נפרדת; חוקי היסוד עליונים מכוחה (שני הכובעים). זו הגישה שהתקבלה כגישה המובילה.
הנשיא שמגר	מקבל את עליונות חוקי היסוד ואת סמכות הביקורת, אך עם דגשים משלו בנוגע למקור הסמכות; מדגיש שהכנסת עצמה ביקשה לעגן זכויות.
השופט חשין	סבור שיש לגלות זהירות, מפקפק ביכולת לקבוע שהכנסת "נעשתה" רשות מכוננת, ומדגיש את הצורך בחקיקה מפורשת של חוקה.

למבחן אין צורך לשנן את הניואנסים של כל שופט. חשוב לזכור את התוצאה (מעמד על-חוקי, סמכות פסילה) ואת המחלוקת המושגית על מקור הסמכות. הביקורת על ברק היא שהוא "יצר" חוקה בלי החלטה מפורשת של העם או של אסיפה מכוננת, ושהכנסת לא ידעה שהיא חובשת כובע מכונן כשחוקקה את חוקי 1992.

2.4 מה נבחן אחרי המהפכה

המהפכה לא ביטלה את עליונות הכנסת באופן מלא. ראשית, חוק רגיל שפוגע בזכות יהיה תקף אם עמד בתנאי פסקת ההגבלה. שנית, הוראת **שמירת דינים** (ס׳ 10 לחוק יסוד: כבוד האדם) מגינה על חקיקה שקדמה לחוק. שלישית, בחוק יסוד: חופש העיסוק קיימת **פסקת התגברות** המאפשרת לכנסת לגבור

בחקיקה ברוב. רביעית, בית המשפט נוקט ריסון, ורובם המכריע של החוקים שנבחנו נותרו בתוקף. פסילת חוק היא נדירה, והראשונה הגיעה רק ב-2009 (הפרטת בתי הסוהר).

- **שלב א:** האם החוק פוגע בזכות חוקתית (פרשנות הזכות).
- **שלב ב:** האם הפגיעה עומדת בפסקת ההגבלה.
- **שלב ג:** הסעד, אם הפגיעה אינה כדין.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שבנק המזרחי פסל את חוק גל - הוא **לא** נפסל. ההלכה נקבעה אגב דחיית העתירה.
- לבלבל בין "שני הכובעים" (מקור העליונות) לבין "שני החוקים" (1992) - אלה מושגים שונים.
- לטעון שהמהפכה נעשתה בחוק יסוד - היא נעשתה בפסיקה, בפרשנות החוקים.

2.5 חוקי היסוד מאז: התפתחויות

בעשורים שאחרי בנק המזרחי פסל בג"ץ חוקים בודדים בלבד. נחקק גם חוק יסוד: הלאום (2018), ועלתה שאלה אם לבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד עצמם. בשנת 2024 (בג"ץ 5658/23) פסל בית המשפט תיקון לחוק יסוד: השפיטה, והכריע ברוב גדול (12 מתוך 15 שופטים) שיש לו סמכות לבקר חוק יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת. עצם הפסילה נקבעה ברוב של 8 מול 7. הנושא נדון בפרק הבא.

★ טיפ למבחן — שלד לתשובה על "המהפכה החוקתית"

- הרקע: מודל ווסטמינסטר, החלטת הררי, חוקי 1992.
- הלכת בנק המזרחי: עליונות ומקור הסמכות (שני כובעים).
- ההסתייגויות: חשין, ביקורת על "מהפכה שיפוטית".
- התוצאה: מבחן חוקתי מבוסס פסקת הגבלה, ריסון בפועל.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק רגיל מגביל בקשות לרישיון עיסוק, ובעל עסק טוען שנפגע חופש העיסוק. מה השלב הראשון? **פתרון:** לבדוק אם החוק פוגע בזכות המוגנת בחוק היסוד (שלב א), ואם כן, האם הוא בחוק, לתכלית ראויה ובמידתיות (שלב ב). רק אם נכשל - הסעד.

2.6 ההשלכות על הרשויות

המהפכה לא נגעה רק לכנסת. ס׳ 11 לחוק יסוד: כבוד האדם מחייב כל רשות מרשויות השלטון לכבד את הזכויות שבחוק, ולכן גם החלטות מנהליות נבחנות מול הזכויות. בנוסף נקבע כלל פרשני: חוק נקרא, ככל האפשר, באופן המתיישב עם זכויות היסוד ("פרשנות מקיימת"). במבחן יש להזכיר ששלושת הכלים (פסילה, פרשנות מקיימת, הלכות מנהליות) פועלים יחד.

2.7 ביקורת על המהפכה ותגובות

המהפכה החוקתית עוררה ביקורת מכמה כיוונים. הביקורת הדמוקרטית טוענת שהעברת הכרעות ערכיות לשופטים בלתי נבחרים מרוקנת את עקרון הכרעת הרוב. הביקורת הפרשנית טוענת שהכנסת של 1992 לא התכוונה להעניק לחוקי היסוד מעמד על-חוקי, ושהעניין נקבע בדיעבד בידי בית המשפט. מנגד, התומכים מצביעים על כך שהכנסת לא תיקנה את חוקי היסוד לאחר הפסיקה, ושבפועל התקבלה הלכת

בנק המזרחי כחלק מהשיטה. הוויכוח הזה חוזר ועולה בפרקים על פסקת ההתגברות ועל ביקורת חוקי היסוד, ולכן כדאי לשלוט בטיעוני שני הצדדים.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- 1992: חוקי זכויות עם פסקת הגבלה; 1995: בנק המזרחי.
- תורת שני הכובעים (ברק): מכונן מול מחוקק.
- שלוש גישות: ברק, שמגר, חשין.
- המהפכה הותירה את הכנסת חזקה: מבחן חוקתי בעל שלבים ופסקאות שמירה והתגברות.

פרק 3

מעמד חוקי היסוד ושריון

3.1 מהו חוק יסוד ומה מעמדו

בהיררכיה הנורמטיבית בישראל חוק יסוד נמצא מעל החוק הרגיל. חוק רגיל שסותר חוק יסוד, שלא בהתאם לפסקת ההגבלה, אינו תקף. לפי בנק המזרחי מקור העליונות הוא **הסמכות המכוננת** של הכנסת. כדי לדעת מהו חוק יסוד נעשה שימוש ב**מבחן צורני**: חוק הנקרא "חוק יסוד: ..." (בלי ציון שנה בשם) הוא חוק יסוד, והכותרת מסמנת את כוונת הכנסת לפעול בכובע המכונן. המבחן הצורני מונע התדיינות על כל חוק שנחשב חשוב מהותית, אך מותיר את השאלה אם הכנסת רשאית לכנות כל דבר "חוק יסוד" (בלי להפר גבולות).

✦ הגדרה — היררכיית הנורמות

חוק יסוד ← חוק רגיל ← חקיקת משנה (תקנות) ← החלטה מנהלית. כל נורמה נבחנת מול הנורמה שמעליה, וחוק רגיל נבחן גם מול חוק היסוד.

3.2 שריון: הגנה על חוק היסוד מפני שינוי

שריון הוא מנגנון המקשה על שינוי הוראה בחוק יסוד, ובכך מבטא נוקשות חוקתית. קיימים כמה סוגי שריון. **שריון פורמלי** דורש רוב מיוחד לשינוי ההוראה (למשל רוב של חברי הכנסת, 61, ובמקרים חריגים 80). **שריון עניני (מהותי)** מתנה פגיעה בהוראה בעמידה בתנאי תוכן, כגון פסקת ההגבלה. עוד כלל נפרד הוא שחוק יסוד משתנה רק בחוק יסוד, ולא בחוק רגיל. דוגמה מובהקת: ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת (עקרון השוויון בבחירות) משוריין ברוב של חברי הכנסת. בחוק יסוד: חופש העיסוק יש הוראת שריון ברוב של חברי הכנסת, ובחוק יסוד: כבוד האדם עצמו אין שריון כללי של תוכן הזכויות.

סוג שריון	מה נדרש לשינוי	דוגמה

פורמלי	רוב מיוחד של חברי הכנסת (61 או 80)	ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת
עניני (מהותי)	שינוי רק בחוק יסוד, לא בחוק רגיל	הוראות המפנות לתיקון "בחוק יסוד"
ללא שריון	תיקון בחוק יסוד ברוב רגיל (אך רק בחוק יסוד)	חלק מחוקי היסוד, כגון כבוד האדם

⚖ פסק דין — ברגמן נ׳ שר האוצר (1969)

חוק מימון מפלגות נתקבל ברוב רגיל, אף שהוראת השוויון בבחירות משוריינת. נקבע שחוק שנחקק בניגוד לשריון בטל. ההלכה היא שהכנסת כבולה בהוראות שריון, גם כשמדובר בשינוי עקיף של ההוראה המשוריינת.

3.3 הבחנה: שינוי חוק יסוד לעומת פגיעה בזכות

שינוי חוק יסוד פירושו תיקון נוסחו. אם הוא משוריין - נדרש הרוב הנדרש. **פגיעה** בזכות פירושה חוק רגיל שפוגע בזכות המעוגנת בחוק היסוד, מבלי לשנות אותו. פגיעה כזו נבחנת בפסקת ההגבלה (פרק 4). ההבחנה חשובה כי לא כל חוק הפוגע בזכות "משנה" חוק יסוד, ולכן אין צורך ברוב מיוחד לכל חוק רגיל שפוגע בזכות. אך הוראת שריון עצמה מחייבת את הכנסת בדרך שבה היא משנה אותה.

3.4 שמירת דינים

ס׳ 10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מורה ש"אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו". כלומר חקיקה שנחקקה לפני מרץ 1992 אינה ניתנת לפסילה בשל סתירה לחוק היסוד. אולם בית המשפט פירש זאת בצמצום: חקיקה ישנה **נפרשת** לאור ערכי היסוד החדשים, ושינוי מהותי או תיקון מאוחר לחוק ישן אינו מוגן. פסקת שמירת הדינים נועדה למנוע פתיחה מחדש של כל חקיקת "דת ומדינה" הקיימת.

§ סעיף — ס׳ 10 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

שמירת תוקפם של דינים שקדמו לחוק היסוד. אינה חלה על חקיקה חדשה, ואינה אוסרת פרשנות מחודשת של הדין הישן.

3.5 גבולות הסמכות המכוננת

שאלה פתוחה היא אם יש גבול לכוח המכונן של הכנסת. בפסיקה התפתחה הדוקטרינה של **שימוש לרעה בסמכות מכוננת**: בג"ץ הציע כי חוק יסוד שפוגע בגרעין הזהות החוקתית (אופי יהודי ודמוקרטי, שלטון חוק, זכויות יסוד) עלול להיפסל. בשנת 2020 דן בית המשפט בעתירות נגד חוקי יסוד שהסדירו ממשלת רוטציה, ודחה אותן אך קבע שבשימוש לרעה בסמכות ניתן להתערב. בשנת 2021 דחה בהרכב מורחב עתירות נגד חוק יסוד: הלאום. ב-2024 פסל בג"ץ (5658/23) תיקון לחוק יסוד: השפיטה, והכריע בעיקרון שיש לבית המשפט סמכות לבקר חוק יסוד במקרים קיצוניים.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- להניח שכל חוק יסוד משוריין - רבים אינם משורייינים.
- לבלבל בין "פגיעה" ל"שינוי": הראשונה נבחנת בפסקת ההגבלה, השנייה בדרישת השריון.
- לחשוב שחוק שנחקק לפני 1992 לעולם אינו ניתן לביקורת - הוא מוגן מפני פסילה, אך נפרש לאור חוק היסוד.

3.6 שלד לפתרון שאלה בנושא

1. האם הנורמה היא חוק יסוד או חוק רגיל (בדיקה צורנית)?
2. האם קיימת הוראת שריון, ומה סוגה?
3. האם החוק נתקבל ברוב הנדרש?

4. אם החוק רגיל והוא סותר חוק יסוד - האם נפגעה זכות ומה דינה בפסקת ההגבלה?
5. האם נדרשת שמירת דינים (חוק קדם ל-1992)?

✎ דוגמה — תרגיל פתור

הכנסת חוקקה ב-1996 תיקון לחוק מ-1960 שפוגע בקניין. האם ס׳ 10 מגן? **פתרון:** לא; התיקון חדש, ולכן אינו נהנה משמירת דינים ונבחן לפי פסקת ההגבלה. אילו החוק לא תוקן - היה מוגן מפני פסילה.

3.7 שינוי חוק יסוד: מי רשאי

הכלל המקובל הוא ש**חוק יסוד משתנה בחוק יסוד**. חוק רגיל אינו יכול לתקן או לבטל הוראה בחוק יסוד, גם אם נתקבל ברוב גדול. מכאן נגזרת גם הבעיה של "הוראות שעה" בחוקי יסוד, שבהן הכנסת משעה זמנית את תוקף הוראה: הן נעשות בחוק יסוד עצמו. מבחינת מבחן, כשמוצג חוק רגיל הסותר חוק יסוד, יש לשאול תחילה האם נעשה ניסיון לשנות את חוק היסוד בעקיפין, כי אז תתעורר שאלת השריון, או שמדובר רק בפגיעה בזכות שנבחנת בפסקת ההגבלה.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- חוק יסוד עליון; חוק רגיל הסותר אותו (שלא כדין) בטל.
- זיהוי חוק יסוד - מבחן צורני.
- שריון: פורמלי (רוב מיוחד) ועניני (שינוי בחוק יסוד).
- שינוי ≠ פגיעה.
- ס׳ 10: שמירת דינים - ישן מוגן, חדש לא.
- גבולות הסמכות המכוננת: שימוש לרעה; הלכת 5658/23.

פרק 4

פסקת ההגבלה

4.1 מקומה של פסקת ההגבלה

זכויות היסוד בישראל אינן מוחלטות אלא **יחסיות**. פסקת ההגבלה היא הכלי המרכזי לקביעה מתי מותר לשלטון לפגוע בזכות חוקתית. היא מופיעה במפורש בשני חוקי היסוד של 1992: **ס׳ 8** לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ו**ס׳ 4** לחוק יסוד: חופש העיסוק. פסקת ההגבלה היא הליבה של הביקורת החוקתית, ולכן כמעט כל שאלה במבחן על פגיעה בזכות תסתיים בה.

§ סעיף — ס׳ 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

4.2 ארבעת התנאים המצטברים

1. **בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת** - נדרשת חקיקה ראשית של הכנסת, או תקנה שהחוק הסמיך אליה במפורש. הסמכה כללית אינה מספיקה, ופגיעה על ידי הנחיה פנימית אינה כדין.
2. **הולם את ערכיה של מדינת ישראל** - מדינה יהודית ודמוקרטית. החוק לא יעמוד אם הוא סותר ערכים אלה.
3. **לתכלית ראויה** - המטרה צריכה להיות חשובה מספיק, לפחות כדי להצדיק פגיעה בזכות. תכלית שהיא עצמה פוגענית (למשל אפליה) אינה ראויה.
4. **במידה שאינה עולה על הנדרש (מידתיות)** - התנאי שבו מוכרעים רוב המקרים.

התנאים מצטברים: אם אחד מהם אינו מתקיים, הפגיעה אינה כדין. **נטל ההצדקה** מוטל על המדינה, שכן היא הפוגעת בזכות. אולם קיימת **חזקת חוקתיות** לחוק שנחקק בידי הכנסת, והמדינה צריכה להוכיח את הצדקתו לאחר שהעותר הראה פגיעה.

4.3 מבחני המידתיות

מבחן משנה	השאלה	דוגמה
התאמה (קשר רציונלי)	האם האמצעי מקדם את התכלית?	איסור בלתי קשור למטרה - נכשל
האמצעי שפגיעתו פחותה	האם אין אמצעי אחר שפוגע פחות ומשיג את אותה תכלית?	אמצעי חלופי סביר קיים - נכשל
מידתיות במובן הצר	האם התועלת שבתכלית גדולה מהנזק לזכות?	איזון תועלת מול נזק

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

בתשובה, עבור על שלושת המבחנים לפי הסדר, והדגש את הקושי המרכזי. לרוב הכשל הוא במבחן השני (האמצעי שפגיעתו פחותה) או בשלישי (המידתיות במובן הצר). הזכר מרווח שיקול הדעת של המחוקק: ככל שהפגיעה קשה יותר, כך הביקורת מחמירה.

4.4 פסקת הגבלה שיפוטית וחקיקה ישנה

בשני חוקי היסוד של 1992 יש פסקת הגבלה כתובה. בחוקי יסוד אחרים אין. במקרים של זכויות בלתי מנויות (ביטוי, שוויון), הפסיקה מיישמת את פסקת ההגבלה של חוק היסוד כאילו חלה על הזכות הנגזרת. חקיקה שקדמה לחוק היסוד מוגנת מפני פסילה בשל שמירת הדינים (ס׳ 10 לחוק כבוד האדם), אך חוק חדש אינו מוגן, וכך גם תיקון מאוחר לחוק ישן.

4.5 פסיקה מרכזית ביישום המידתיות

⚖ פסק דין — בית סוריק (בג"ץ 2056/04)

תוואי גדר ההפרדה באזור בית סוריק פגע בחיי היום-יום של תושבים פלסטינים. הנשיא ברק יישם את מבחני המידתיות ונקבע שחלק מהתוואי אינו מידתי, והמדינה נדרשת לשנותו. ההלכה: גם החלטות ביטחוניות כפופות לביקורת מידתיות, והמדינה צריכה להצדיק מדוע לא נבחר תוואי הפוגע פחות.

⚖ פסק דין — אדם נ׳ הכנסת (בג"ץ 7146/12, 2013)

תיקון לחוק למניעת הסתננות אפשר לעצור מסתננים עד שלוש שנים בלי משפט. ההרכב המורחב פסל את ההוראה: פגיעה בלתי מידתית בחירות ובכבוד האדם. ההלכה: גם כשהתכלית (הרתעה, הגנה על שוק העבודה) ראויה, האמצעי חייב לעמוד במבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ובמבחן הצר.

⚖ פסק דין — עדאלה נ׳ שר הפנים (בג"ץ 7052/03, 2006)

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) מנע איחוד משפחות בין אזרחי ישראל לתושבי השטחים. בית המשפט, ברוב של שישה שופטים מול חמישה, דחה את העתירות. נקבע שהחוק פוגע בזכות לחיי משפחה כחלק מהכבוד, אך עומד במבחני ההגבלה, בהתחשב בנימוקי הביטחון. ההלכה: אפילו פגיעה קשה יכולה להיחשב מידתית כשמדובר בביטחון, ולכן המחלוקת במידתיות בין השופטים היא עניין של קביעת ערכים.

4.6 מלכודות נפוצות

טעות	הנכון
לבדוק רק "תכלית ראויה" ולעצור	יש לבדוק את ארבעת התנאים, ובעיקר מידתיות
לטעון שפגיעה בזכות היא בלתי חוקתית אוטומטית	פגיעה המקיימת את הפסקה כדין
להניח שהכנסת רשאית לפגוע בכל זכות בחוק	רק אם עמד בהגבלה; אחרת נפסל החוק רגיל
לבלבל בין "התאמה" ל"אמצעי שפגיעתו פחותה"	התאמה: האם האמצעי עובד; אמצעי פחות פוגע: האם יש חלופה

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק אוסר על קבוצת עובדים לעבוד בענף מסוים מטעמי ביטחון, אך ניתן להשיג את אותה מטרה בבדיקות ביטחוניות פרטניות. **פתרון:** פגיעה בחופש העיסוק; התכלית ראויה; האמצעי מתאים; אבל קיים אמצעי שפגיעתו פחותה (בדיקות פרטניות), ולכן נכשל מבחן המשנה השני והחוק אינו מידתי.

4.7 מתחם המידתיות ושיקול דעת המחוקק

מידתיות אינה נקודה אחת אלא **מתחם** של אמצעים סבירים. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת המחוקק ברגע שהאמצעי שנבחר נמצא בתוך המתחם, גם אם הוא אינו האמצעי האידיאלי. לכן נדרש לבדוק לא אם קיים אמצעי טוב יותר בהכרח אלא אם קיים אמצעי פחות פוגע **המשיג את אותה תכלית באופן דומה**. חשוב גם לזכור שדרגת הביקורת אינה זהה בכל התחומים: כשמדובר בפגיעה בליבת הזכות, יידרש נימוק כבד יותר, ובתחומי מדיניות כלכלית רחבים המחוקק נהנה ממרווח גדול יותר.

4.8 הקשר לפסקאות האחרות

פסקת ההגבלה פועלת יחד עם שמירת הדינים (חקיקה ישנה מוגנת), ההתגברות (בחופש העיסוק בלבד) והפרשנות המקיימת. בפועל, עורך דין בוחן קודם כול אם חל חוק יסוד, ואם נפגעה זכות מוגנת. רק אחר כך הוא עובר לפסקת ההגבלה, ואם היא נכשלת בוחן את הסעד: פסילה מיידית, בטלות מושהית או פרשנות מקיימת. הסדר הזה חוסך טעויות נפוצות, כגון דילוג על שלב הפגיעה.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- ס׳ 8 (כבוד האדם) וס׳ 4 (חופש העיסוק).
- ארבעה תנאים מצטברים: בחוק, ערכים, תכלית ראויה, מידתיות.
- שלושה מבחני משנה: התאמה, פגיעה פחותה, מידתיות במובן הצר.
- נטל על המדינה; בית סוריק, אדם, עדאלה.

פרק 5

פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

5.1 מהי פסקת ההתגברות ומדוע נוצרה

פסקת ההתגברות היא מנגנון המאפשר לכנסת לחוקק חוק רגיל הפוגע בזכות חוקתית גם אם החוק אינו עומד בפסקת ההגבלה. זהו שסתום ביטחון שנועד לאפשר לרוב הפרלמנטרי "לקבל את המילה האחרונה" בנושאים שנויים במחלוקת. כיום פסקה כזו קיימת בישראל **רק בחוק יסוד: חופש העיסוק (ס׳ 8)**, ולא בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כשאומרים "פסקת ההתגברות" בלי תוספת, הכוונה היא לה.

§ סעיף — ס׳ 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק

חוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת, ונאמר בו במפורש שהוא תקף "על אף האמור בחוק יסוד זה", תקף גם אם אינו עומד בפסקת ההגבלה. תוקפו של חוק כזה פוקע בתום **ארבע שנים** מיום קבלתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

תנאי	תוכן
אמירה מפורשת	החוק מציין שהוא תקף "על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוק"
רוב	לפחות 61 חברי כנסת (רוב חברי הכנסת, ולא רוב הנוכחים)
הגבלת זמן	ארבע שנים לכל היותר; לאחר מכן החוק פוקע
היקף	חל על הוראות פוגעות בחופש העיסוק בלבד

5.2 הרקע: פרשת מיטראל ויבוא הבשר

פסקת ההתגברות נולדה כתגובה לפסיקה בעניין **מיטראל**. חברה ביקשה לייבא בשר שאינו כשר, והרשויות סירבו לה מכוח מדיניות שהתבססה על שיקולי כשרות. בג"ץ קבע שהמדיניות פוגעת בחופש העיסוק ללא בסיס חקיקתי מפורש. כדי לאפשר את ההסדר בכל זאת, הוסיפה הכנסת את פסקת ההתגברות לחוק

יסוד: חופש העיסוק (1994) וחוקקה מכוחה את חוק יבוא בשר. הדוגמה המובהקת הזו מלמדת שהמנגנון נועד לעקוף פסילות שיפוטיות בנושאים עקרוניים של דת ומדינה, ולא רק לפעול כשלב בחקיקה רגילה.

⚖ פסק דין — מיטראל בע"מ נ׳ ראש הממשלה (בג"ץ 3872/93) ובג"ץ 4676/94

לאחר שבג"ץ פסל את מדיניות איסור היבוא, חוקקה הכנסת חוק יבוא בשר בפסקת התגברות. בעתירה נוספת נגד החוק החדש נדחתה הטענה, כי החוק עמד בתנאי הפסקה (אמירה מפורשת ורוב), ולכן הפגיעה בחופש העיסוק לא נבחנה שוב בפסקת ההגבלה.

5.3 ההיבטים הביקורתיים ובחינה השוואתית

הוויכוח סביב ההתגברות הוא בין שני ערכים: מצד אחד **ריבונות העם** דרך נציגיו, ומצד שני **הגנה על זכויות** גם מפני רוב. התומכים טוענים שהמנגנון משמר את הדמוקרטיה ומונע "שלטון שופטים". המתנגדים טוענים שהוא מרוקן את עליונות הזכויות. הפתרון הישראלי מתון יחסית: דרישת רוב מוחלט, אמירה מפורשת (המקשה על הסתרה) והגבלת זמן. הצעות לחוקק פסקת התגברות רחבה לכל חוקי היסוד, או כזו שמאפשרת לגבור על פסילת בג"ץ, הועלו ואינן חלק מהדין הקיים.

	ישראל (חופש העיסוק)	קנדה (הצהרה על "אף האמור", ס׳ 33)
מי רשאי לגבור	הכנסת	הפרלמנט / בית המחוקקים
רוב נדרש	רוב חברי הכנסת	רוב רגיל
תוקף	ארבע שנים	חמש שנים
היקף	חופש העיסוק בלבד	חלק מהזכויות בצ׳רטר

5.4 היחס בין חוקי היסוד

אין היררכיה פנימית בין חוקי היסוד. כולם עומדים באותה דרגה נורמטיבית. כשיש סתירה או ספק בין חוקי יסוד, הכלל הוא **הרמוניה חקיקתית**: יש לפרש אותם כך שכולם יתקיימו ככל האפשר. כאשר ההרמוניה

אינה אפשרית, מופעלים כללי הכרעה רגילים: חוק יסוד ספציפי גובר על כללי, ובמידת הצורך חוק מאוחר גובר על מוקדם. כמו כן, חוק יסוד אחד יכול להגביל זכות שבחוק יסוד אחר, ולכן בנושאים כמו סמכויות הממשלה או הכנסת, יש לבחון בכל מקרה גם את חוק היסוד הרלוונטי.

✦ הגדרה — הרמוניה חקיקתית

עיקרון פרשני לפיו נורמות באותה דרגה יפורשו כך שיתיישבו ביניהן, ולא יבטלו זו את זו, אלא כשאין ברירה.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שיש פסקת התגברות גם בחוק יסוד: כבוד האדם - אין.
- לשכוח שהחוק פוקע לאחר ארבע שנים וניתן לחוקקו מחדש רק בהליך חדש העומד בתנאים.
- לחשוב שהפסקה "מבטלת" את הזכות - היא רק מונעת פסילה בשל פגיעה בחופש העיסוק, והחוק עדיין כפוף לביקורת אחרת (שוויון, הליך).
- לבלבל בין פסקת ההגבלה (ס׳ 4 לחופש העיסוק) לבין ההתגברות (ס׳ 8).

5.5 שלד לפתרון שאלה

1. האם החוק פוגע בחופש העיסוק? אם כן, האם נכלל בו תנאי "על אף"?
2. האם התקבל ברוב של 61 חברי כנסת לפחות?
3. האם לא חלפו ארבע שנים?
4. אם כל התנאים התקיימו - החוק תקף גם בלי מידתיות. אחרת - נבחן בפסקת ההגבלה.
5. הוסף בחינה של פגיעה בזכויות אחרות שאינן בחוק העיסוק.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק רגיל מגביל יבוא מוצר, נתקבל ב-70 קולות, ללא אמירת "על אף". האם הוא תקף? **פתרון:** אין אמירה מפורשת, ולכן ההתגברות לא חלה; החוק יבחן בפסקת ההגבלה. אם הוא מידתי - יעמוד; אחרת יפסל.

5.6 האם ניתן לבקר שימוש בהתגברות

שאלה פתוחה היא האם בית המשפט רשאי לבקר שימוש בפסקת ההתגברות מעבר לבדיקת התנאים הפורמליים. הגישה המקובלת היא שמשעמדו התנאים, אין עילה לפסול את החוק בשל פגיעה בחופש העיסוק. עם זאת, בפסיקה נשמעו קולות שלפיהם שימוש לרעה בפסקה, למשל חקיקה שחוזרת וממשיכה את ההתגברות בלי שקילה אמיתית או חקיקה פוגענית ביסודות המשטר, עשוי להיבחן במסגרת הדוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות. הסוגיה לא הוכרעה סופית, ולכן במבחן עדיף לנסח בזהירות ולהצביע על הצדדים.

5.7 מבט השוואתי ופרשני נוסף

מעבר להשוואה לקנדה, ראוי להבחין בין התגברות על פסילה שיפוטית קיימת (כמו בפרשת יבוא הבשר, שבה החקיקה באה אחרי הפסיקה) לבין התגברות מראש, שבה החוק נחקק בלי פסיקה קודמת. בשני המקרים התנאים זהים, אך המשמעות הציבורית שונה: התגברות בעקבות פסיקה נתפסת כפולמוס בין הכנסת לבית המשפט, בעוד התגברות מראש נתפסת כהכרעה מדינית מוצהרת. בפרקטיקה השימוש בפסקה נדיר, וזו אחת הסיבות לכך שהיא נתפסת כאמצעי חריג.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- ההתגברות בס׳ 8 לחופש העיסוק בלבד.
- תנאים: אמירה מפורשת, 61 ח"כ, תוקף 4 שנים.
- נולדה בעקבות מיטראל ויבוא הבשר.
- אין היררכיה בין חוקי היסוד; הרמוניה חקיקתית.

פרק 6

ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

6.1 הביקורת השיפוטית ושערי הכניסה לבג"ץ

ביקורת שיפוטית היא סמכות בית המשפט לבחון את חוקיות מעשי השלטון, ובכלל זה חוקתיות החקיקה. הוויכוח הציבורי עוסק בציר שבין **אקטיביזם שיפוטי** (התערבות נרחבת להגנה על זכויות ושלטון החוק) לבין **ריסון שיפוטי** (כיבוד שיקול דעתן של הרשויות הנבחרות). מי שמבקש לתקוף חקיקה או החלטת שלטון בבג"ץ חייב לעבור כמה "שערים": זכות עמידה, שפיטות, וכן תנאים נוספים כמו בשלות, היעדר שיהוי וניסיון מיצוי הליכים. כל אחד מהם יכול להביא לדחיית העתירה על הסף.

✦ הגדרה — בג"ץ

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. מכוח ס׳ 15 לחוק יסוד: השפיטה הוא דן בעניינים שבהם יש צורך לתת סעד "למען הצדק" ושאינם בסמכות ערכאה אחרת, ובכלל זה עתירות נגד רשויות השלטון. מדובר בערכאה ראשונה, ללא דיון קודם בערכאה נמוכה.

6.2 זכות עמידה

בעבר נדרש שהעותר יהיה **נפגע ישיר**, כלומר מי שהחלטת הרשות פוגעת בו באופן אישי. עם השנים הורחבה הזכות מאוד. הוכר ה**עותר הציבורי**: אדם או ארגון שעותר בעניין בעל חשיבות ציבורית כללית, גם בלי אינטרס אישי ישיר. ככלל מכירים בעותר ציבורי כשמדובר בשאלה חוקתית עקרונית, בפגיעה בשלטון החוק או בטוהר המידות, או כשהפגיעה כללית עד כדי כך שאין נפגע ישיר מובהק. ברוב המקרים בית המשפט ינהג בריסון כשקיים נפגע ישיר היכול לעתור בעצמו ואינו עושה זאת, או כשהעותר הציבורי מבקש להתערב בנושא שאינו בעל חשיבות כללית.

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

כשנשאלת שאלה על זכות עמידה, פתח בכלל ההיסטורי (נפגע ישיר), העבר להרחבה (עותר ציבורי) והסבר מדוע הרחבה זו מתיישבת עם שלטון החוק, ואחר כך יישם: האם הנושא ציבורי? האם יש נפגע ישיר? האם העותר מייצג אינטרס כללי?

6.3 שפיטות: נורמטיבית ומוסדית

סוג	השאלה	עמדת הפסיקה
שפיטות נורמטיבית	האם קיימת אמת מידה משפטית להכרעה?	כמעט תמיד כן: "הכול שפיט", לכל פעולה יש היבט של חוקיות
שפיטות מוסדית	האם ראוי שדווקא בית המשפט יכריע?	בדרך כלל כן; חריגים נדירים לעניינים שמתאימים להכרעה פוליטית

⚖ פסק דין — רסלר נ׳ שר הביטחון (בג"ץ 910/86, 1988)

העותר ביקש לתקוף את מדיניות דחיית השירות של תלמידי ישיבות, אף שלא היה נפגע ישיר. בית המשפט קבע שהעותר רשאי לעתור, והכיר בכך שהנושא שפיט. ההלכה: הרחבת הזכות לעותר ציבורי, והבחנה בין שפיטות נורמטיבית (כמעט תמיד קיימת) לבין שפיטות מוסדית (נבחנת בנסיבות). מהלכה זו התפתחה גישת "הכול שפיט", שהרחיבה את סמכות בג"ץ בתחומי ביטחון וחוץ.

הסיבה לביקורת על ההרחבה היא שהיא מושכת לבית המשפט סוגיות פוליטיות ומפחיתה את אחריותן של הכנסת והממשלה. התומכים מדגישים שאין תחום "נקי" משלטון החוק, ושגם הכרעה שבית המשפט נמנע ממנה היא לעתים הכרעה מדינית. בפועל בית המשפט נוקט ריסון באמצעות תנאים אחרים, כגון מתחם הסבירות והמידתיות, ואינו נמנע מדיון עקרוני.

6.4 בשלות ועילות סף נוספות

בשלות פירושה שהעתירה אינה מוקדמת מדי: הנושא התגבש מספיק כדי שאפשר יהיה להכריע בו. עתירה שהגיעה לפני שהחוק יושם בפועל, או שהפגיעה אינה אלא תיאורטית, עלולה להידחות. מנגד, דחייה על הסף עלולה להרתיע עותרים עתידיים ("אפקט מצנן"). **שיהוי** הוא עיכוב בלתי סביר בהגשת העתירה, העלול לפגוע בצדדים שלישיים. **אקדמיות** היא עתירה שהפכה תיאורטית. **מיצוי הליכים** דורש לפנות קודם לרשות או לערכאה המתאימה.

⚖ פסק דין — סבח נ׳ הכנסת (בג"ץ 2311/11, 2014)

נדונו עתירות נגד חוק ועדות קבלה ליישובים קהילתיים. בית המשפט דחה את העתירות בשל היעדר בשלות, כי החוק עדיין לא יושם בפועל והיה קשה לבחון אם הוא פוגע. ההלכה: ביקורת חוקתית אפשרית גם מראש, אך כשהפגיעה תלויה ביישום ולא בנוסח החוק, ניתן להמתין. פרטי הרוב אינם חיוניים למבחן.

⚖ פסק דין — חוק טל (בג"ץ 6427/02 ובג"ץ 6298/07)

חוק טל הסדיר את דחיית השירות של תלמידי ישיבות. ב-2006 נבחנה חוקתיות החוק, ונקבע שהוא פוגע בשוויון, אך הוא נבחן במבחן מציאות: אם לא יושג שינוי בפועל, ייפסל. החוק הוארך, וב-2012 נקבע כי הוא אינו חוקתי. ההלכה: בשלות ובחינת יישום בפועל כמבחן לחוקתיות. פרטי התאריכים והרוב נשארים בכלליות.

6.5 הסעדים

כשחוק אינו חוקתי, הסעד הרגיל הוא **בטלות**. אך יש כלים מתונים: **בטלות חלקית** (פסילת הוראה בלבד כשהשאר מתקיים), **בטלות מושהית** (הצהרה על אי-חוקתיות עם דחיית הבטלות לפרק זמן כדי לאפשר

לכנסת לתקן), ו**פרשנות מקיימת** (פרשנות הנוסח כך שיעמוד בחוק היסוד, ללא פסילה). בית המשפט מעדיף את הכלי המתון ביותר שמקיים את חוקי היסוד.

סעד	תיאור	מתי
בטלות	החוק בטל	כשאי אפשר לתקן, או כשהפגיעה חמורה
בטלות חלקית	בטלות הוראה בודדת	כשההוראה ניתנת להפרדה
בטלות מושהית	בטלות מועד אחר	לפרק זמן כדי לאפשר חקיקה מתקנת
פרשנות מקיימת	פרשנות המתיישבת עם חוק היסוד	כשהנוסח מאפשר

⚖ פסק דין — הפרטת בתי הסוהר (בג"ץ 2605/05, 2009)

הכנסת חוקקה תיקון לפקודת בתי הסוהר שהתיר ניהול בית סוהר בידי חברה פרטית. בג"ץ פסל את התיקון כפגיעה בכבוד ובחירות האסירים, והורה על השהיית הבטלות לתקופה כדי לאפשר הערכות. ההלכה: פסילה ראשונה של חוק, והדגמת סעד של בטלות מושהית.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- להניח ש"שפיט" פירושו שבית המשפט תמיד יתערב - הוא קובע רק שמותר לדון.
- לבלבל בין שפיטות נורמטיבית למוסדית.
- לחשוב שעותר ציבורי אינו צריך להוכיח דבר - עליו להוכיח חשיבות ציבורית.
- לשכוח שבשלות היא דוקטרינה שונה מזכות העמידה.

6.6 שלד לפתרון שאלה

1. האם לעותר יש זכות עמידה (נפגע ישיר או עותר ציבורי)?

2. האם העניין שפיט (נורמטיבית ומוסדית)?
3. האם העתירה בשלה, ללא שיהוי ובלי מיצוי הליכים חסר?
4. בחינת הפגיעה בזכות ופסקת ההגבלה.
5. בחירת סעד מתון: פרשנות, בטלות חלקית, בטלות מושהית או בטלות.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

ארגון ציבורי עותר נגד חוק שעדיין לא נכנס לתוקף ואינו מיושם. **פתרון:** זכות העמידה מוכרת כעותר ציבורי אם הנושא עקרוני; אך ייתכן שהעתירה לא בשלה. בית המשפט עשוי לדחות מחמת היעדר בשלות, אך להשאיר פתח לעתירה עתידית כשהחוק יושם.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שערים: עמידה, שפיטות, בשלות, שיהוי, מיצוי.
- עמידה: מנפגע ישיר לעותר ציבורי (רסלר).
- שפיטות נורמטיבית מול מוסדית.
- סעדים: בטלות, חלקית, מושהית, פרשנות מקיימת.

פרק 7

ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

7.1 שתי רמות של ביקורת על הכנסת

בית המשפט יכול לבקר את הכנסת בשתי רמות. הראשונה היא ביקורת על **תוכן** החוק, כלומר האם הוא סותר חוק יסוד (פסקת ההגבלה, פרק 4). השנייה היא ביקורת על **הליך החקיקה**, כלומר האם החוק נתקבל כדין. לצד זאת קיימת ביקורת על החלטות **פנים-פרלמנטריות** (סדרי דיון, החלטות ועדות, החלטות יו"ר הכנסת). הפרק הזה עוסק בשני הסוגים האחרונים, שבהם בית המשפט נוקט ריסון מיוחד מתוך כבוד להפרדת הרשויות ולאוטונומיה של הפרלמנט.

7.2 הליך החקיקה בקצרה

הצעת חוק יכולה להיות **ממשלתית**, **של חבר כנסת** (הצעה פרטית) או **של ועדה**. החוק עובר שלוש קריאות במליאה, עם דיון בוועדה בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית. בכל שלב אפשר להציע הסתייגויות והצעות תיקון. רוב החקיקה נעשית ברוב רגיל של הנוכחים, אך הוראות משוריינות מחייבות רוב מיוחד. משלב הקריאה הראשונה מתחיל דיון מעמיק יותר בוועדה, ושם נקבע מרבית הנוסח. אחרי הקריאה השלישית החוק מתפרסם ברשומות ונכנס לתוקף במועד שנקבע.

שלב	עיקרו
הנחת הצעה	הממשלה, ח"כ או ועדה מניחים הצעת חוק על שולחן הכנסת
קריאה ראשונה	דיון עקרוני והעברה לוועדה
ועדה	דיון מפורט, הכנת נוסח לקריאה שנייה ושלישית
קריאה שנייה ושלישית	הצבעה על סעיפים ועל הנוסח הסופי
פרסום	רשומות; כניסה לתוקף

7.3 אי-התערבות בענייני הפנים של הכנסת

הכלל הוא שבית המשפט ממעט להתערב בהליכים הפנימיים של הכנסת: סדרי הדיון, שיקול דעתו של יו"ר הכנסת, החלטות ועדות והצבעות. הנימוק הוא כבוד להפרדת הרשויות ולאוטונומיה הפרלמנטרית. אך אין זו חסינות מוחלטת. **מבחן שריד** קובע שבית המשפט יתערב רק כשיש פגיעה קשה ב"מרקם החיים הפרלמנטריים" או בעקרונות היסוד של המשטר החוקתי. ככל שהפגיעה חמורה יותר ובעלת היבט חוקתי ברור, כך גוברת נכונות בית המשפט להתערב.

⚖ פסק דין — שריד נ' יו"ר הכנסת (בג"ץ 652/81, 1982)

עתירה נגד החלטת יו"ר הכנסת בעניין הליך פנימי. בית המשפט קבע כלל של התערבות מצומצמת: הוא יבדוק החלטות פנימיות של הכנסת רק כשיש פגיעה ממשית בעקרונות היסוד של ההליך הפרלמנטרי. ההלכה: אוטונומיה פרלמנטרית היא יחסית, והתערבות נעשית לפי חומרת הפגם.

7.4 פגם בהליך החקיקה

פגם בהליך החקיקה יביא לבטלות רק אם הוא **יורד לשורש ההליך**: פגם חמור הפוגע בעקרונות היסוד של החקיקה הדמוקרטית, כגון שלילת יכולתם של חברי כנסת לגבש עמדה ולהצביע בצורה מושכלת. פגמים קלים, כמו פגיעה בנוהל פנימי שאינה משפיעה על ההכרעה, אינם מצדיקים התערבות. בית המשפט מביא בחשבון גם את שאלת ההתחשבות בציבור ואת עיתוי העתירה.

⚖ פסק דין — מגדלי העופות (בג"ץ 4885/03, 2004)

נתקף חוק ההסדרים הכלכלי, שהכיל עשרות נושאים נפרדים והובא לאישור מהיר. בית המשפט מתח ביקורת על שיטת החקיקה הזו, המקשה על חברי הכנסת לקיים דיון ענייני, ופסק שיש בה פגם. עם זאת, הוא נמנע מלבטל את החוק, ונתן אזהרה כי המשך השימוש בשיטה זו עלול להצדיק התערבות בעתיד. ההלכה: פגם קיים אך ריסון בפועל.

⚖ פסק דין — קוונטינסקי נ׳ הכנסת (2017)

עתירה נגד אופן חקיקתו של חוק בעל השפעה כלכלית. נדון המבחן של פגם היורד לשורש ההליך, ובו נבחנת הפגיעה בעקרונות היסוד של ההליך הפרלמנטרי, ובכללם עקרון ההשתתפות. יש להסתמך על ההלכה העקרונית.

7.5 התערבות בהחלטות יו"ר הכנסת ובסדרי הדיון

בעשורים האחרונים התערב בג"ץ במקרים מסוימים. הדוגמה הבולטת היא בשנת 2020, כשיו"ר הכנסת סירב לקיים הצבעה על בחירת יו"ר חדש: בג"ץ הורה לקיים את ההצבעה, בנימוק שהסירוב פוגע בעקרונות היסוד של המשטר הפרלמנטרי ולא נבע משיקול הדעת הפנימי הרגיל. הדוגמה ממחישה שהאוטונומיה אינה מוחלטת כשמדובר בהליך שמשפיע על כלל מערכת השלטון.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שלבית המשפט אין סמכות לבקר את הליך החקיקה - יש, אך מצומצמת.
- לבלבל בין ביקורת על תוכן (חוק יסוד) לבין ביקורת על הליך.
- להניח שכל פגם בהליך מביא לבטלות - רק פגם היורד לשורש.
- לשכוח את ההבדל בין הכרעה על חוקיות (שפיטה) לבין הכרעה על מדיניות.

7.6 שלד לפתרון שאלה

1. האם הטענה היא לתוכן החוק או להליך החקיקה?
2. אם הליך - האם מדובר בעניין פנימי של הכנסת?
3. החל מבחן שריד: פגיעה בעקרונות היסוד או במרקם החיים הפרלמנטריים.
4. האם הפגם יורד לשורש ההליך (פגיעה ממשית בהשתתפות)?
5. בחר סעד: דחייה, אזהרה או בטלות.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק שהכיל עשרות נושאים הובא לאישור במליאה בלילה אחד, וחברי כנסת טענו שלא יכלו לקרוא אותו. **פתרון:** אין התערבות אוטומטית; יש לבדוק אם הפגם יורד לשורש ההליך. לפי מגדלי העופות, גם כשיש פגם מתחשבים בריסון, ובית המשפט עשוי להסתפק באזהרה.

7.7 תפקיד היועץ המשפטי של הכנסת וחזקת התקינות

בהליך החקיקה פועל היועץ המשפטי של הכנסת, המייעץ ליו"ר ולוועדות בשאלות של חוקיות ההליך ותוכן ההצעות. עצם העובדה שהכנסת מקיימת בקרה פנימית מחזקת את הנימוק לריסון חיצוני: כשיש מנגנון פנימי, אין סיבה שבית המשפט יחליף אותו. ככלל חלה **חזקת תקינות** לגבי הליכי חקיקה, והעותר נדרש להוכיח את הפגם. כדי להצליח, העותר צריך להצביע על פגם ממשי, על השפעתו על ההכרעה, ועל כך שלא היה ניתן לתקן אותו בהליך הפנימי. בנוסף, ככל שהעתירה מוגשת מוקדם יותר, בעוד ההליך מתנהל, יש לבית המשפט יותר אפשרות להתערב באופן מתון, כלומר להורות לתקן, מאשר לפסול חוק שנחקק זה מכבר.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שתי רמות: תוכן והליך.
- ריסון בענייני פנים; מבחן שריד.
- פגם היורד לשורש ההליך - רק אז בטלות.
- מגדלי העופות: ביקורת וריסון; התערבות בנסיבות חריגות.

פרק 8

זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

8.1 המצב עד 1992: זכויות ללא עיגון חוקתי

עד חקיקת חוקי היסוד של 1992 לא היה לזכויות האדם בישראל עיגון חוקתי מפורש. הכנסת הייתה ריבונית, ויכלה, מבחינה פורמלית, לחוקק חוק הפוגע בכל זכות, ולבית המשפט לא הייתה סמכות לפסול אותו. ועם זאת, זכויות האדם הוכרו והוגנו הלכה למעשה, בעיקר דרך הפסיקה. הבנת השיטה שלפני 1992 חשובה משום שהיא מסבירה מה בדיוק שינתה "המהפכה החוקתית": לא את עצם קיומן של זכויות, אלא את מעמדן הנורמטיבי ואת סמכות בית המשפט להגן עליהן מפני חקיקה.

8.2 שלושה מקורות להכרה בזכויות

1. **מגילת העצמאות** - הכריזה על שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור, על חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. אין לה מעמד חוקתי מחייב כשלעצמה, אך היא משמשת כלי פרשני ומקור השראה לעקרונות היסוד של השיטה.
2. **חקיקה רגילה** - חוקים שהגנו על זכויות מסוימות, כמו חוק שוויון זכויות האישה (1951), חוק הגנת הפרטיות (1981) וחוק איסור לשון הרע.
3. **הפסיקה** - "מגילת זכויות שיפוטית": בית המשפט העליון הכיר בזכויות יסוד רבות כעקרונות יסוד של השיטה, אף שלא היו כתובות בחוק.

⚖ פסק דין — קול העם (בג"ץ 73/53, 1953)

שר הפנים סגר שני עיתונים (קול העם ואל-אתיחאד) בטענה שהם מסכנים את שלום הציבור. בית המשפט, מפי השופט אגרנט, ביטל את הסגירה: חופש הביטוי הוא יסוד המשטר הדמוקרטי, וסמכות השר תיפרש בצמצום. נקבע מבחן **הוודאות הקרובה**: אפשר להגביל ביטוי רק כשיש ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. ההלכה ניתנה לפני כל עיגון חוקתי, והיא דוגמה מובהקת להגנה פרשנית.

8.3 הכוח והמגבלה של ההגנה השיפוטית

מה יכלה הפסיקה לעשות? היא פירשה חוקים כך שיקיימו זכויות, לפי **חזקה פרשנית** שהמחוקק לא התכוון לפגוע בזכות יסוד אלא אם אמר זאת במפורש. היא ריסנה את הרשות המבצעת באמצעות עקרון חוקיות המנהל, כללי הצדק הטבעי והסבירות. ומה לא יכלה? לפסול חוק מפורש של הכנסת. כשהמחוקק אמר במפורש שהוא פוגע בזכות, לא עמד לבית המשפט כלי לביטול. לכן ההגנה הייתה חלשה מול חקיקה מפורשת, בשונה ממצב אחרי 1992.

	לפני 1992	אחרי 1992 ו-1995
מעמד הזכויות	עקרונות יסוד שיפוטיים	זכויות חוקתיות מנויות ובלתי מנויות
פגיעה בחוק מפורש	תקפה	תקפה רק אם עמדה בפסקת ההגבלה
סמכות בג"ץ	פרשנות וביקורת מנהלית	גם פסילת חוק רגיל
נטל ההצדקה	לרוב על הפרט	על הרשות הפוגעת

8.4 דוגמאות לפסיקה מוקדמת

⚖ פסק דין — ברגמן נ׳ שר האוצר (1969)

חוק מימון מפלגות העדיף מפלגות קיימות ונחקק ללא הרוב המשוריין. בית המשפט קבע שאינו תקף. ההלכה: שוויון בבחירות הוא עקרון יסוד, והכנסת כבולה בהוראת שריון. זה ביטוי מוקדם להגנה על שוויון, אך מכוח שריון פורמלי ולא מכוח זכות חוקתית כללית.

⚖ פסק דין — שניצר נ׳ הצנזור הצבאי הראשי (בג"ץ 680/88, 1989)

הצנזור פסל פרסום של מאמר עיתונאי בנושא ביטחוני. בית המשפט קבע שגם בעניינים ביטחוניים יש להחיל את מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית בביטחון, ופסל את שיקול הדעת הרחב של הצנזור. ההלכה: חופש הביטוי נחשב זכות על גם בלי עיגון חוקתי, וגם בנושאי ביטחון.

⚖ פסק דין — אל-על נ׳ דנילוביץ (בג"ץ 721/94, 1994)

אל-על העניקה הטבות כרטיסי טיסה לבני זוג של עובדים, אך סירבה להעניק אותן לבן זוגו של דיילת-גבר שחי בזוגיות חד-מינית. בית המשפט קבע שזו הפליה אסורה. ההלכה: עקרון השוויון חל גם על מעסיקים והוא נגזר מעקרונות היסוד של השיטה, ולא נדרש עיגון חוקתי כדי להחילו.

8.5 מצב החירום ותקנות ההגנה

אחד המאפיינים של התקופה שלפני המהפכה הוא מצב החירום שהוכרז ב-1948 ונמשך בהארכות חוזרות. מכוחו נשארו בתוקף תקנות שעת חירום רחבות, כולל תקנות ההגנה (שעת חירום) מ-1945, ומגבלות על

חירויות. כאשר חוק היסוד: כבוד האדם נחקק, נקבע (ס׳ 12) שתקנות שעת חירום לא יפגעו בזכויות אלא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. המשמעות היא שהמהפכה צמצמה גם את כוחן של תקנות החירום, אף ששמירת הדינים המשיכה להגן על חלק מהדין הקיים.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שלפני 1992 לא הוגנו זכויות כלל - הוגנו בפסיקה.
- לטעון שמגילת העצמאות חוקה מחייבת - היא מקור פרשני בלבד.
- להניח שבית המשפט יכל לפסול חוק פוגע לפני 1995 - בפועל פסל רק כשהכנסת לא עמדה בשריון (ברגמן).
- לבלבל בין חזקה פרשנית (נגד פגיעה בזכות) לבין סמכות פסילה.

8.6 שלד לפתרון שאלה

1. זהה את הזכות ואת מקורה: חוק, פסיקה או חוק יסוד.
2. בדוק אם קיים חוק מפורש הפוגע בזכות.
3. אם כן - הפרשנות המקיימת אינה אפשרית; אם לא - החל חזקה פרשנית ופרש לטובת הזכות.
4. בדוק אם הרשות המבצעת פעלה בהסמכה ברורה.
5. ציין מה השתנה אחרי 1992.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

שר סוגר עיתון בטענה שהוא מסית, בלי הסמכה מפורשת למקרה זה. **פתרון:** מדובר בהחלטה מנהלית. גם לפני 1992 יפרש בית המשפט את הסמכות בצמצום, וידרוש ודאות קרובה לפגיעה בשלום הציבור (קול העם). אין צורך בחוק יסוד כדי לפסול את ההחלטה.

8.7 מדוע חשוב להכיר את השיטה הקודמת

השאלה מה היה לפני 1992 חוזרת במבחנים משלוש סיבות. ראשית, שמירת הדינים (ס׳ 10) פירושה שחוקים ישנים עדיין חלים ולכן ההיסטוריה משפיעה על התוצאה. שנית, הפרשנות המקיימת של חוקים ישנים נשענת על ערכי היסוד שפותחו בפסיקה לפני המהפכה. שלישית, הפסיקה המוקדמת (קול העם, ברגמן) משמשת כבסיס להכרה בזכויות בלתי מנויות. לכן מי שמבין את המצב הקודם מבין מדוע חוקי היסוד לא חולל שינוי בנקודה אחת אלא המשך של תהליך.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- לפני 1992: ללא עיגון חוקתי; הגנה פרשנית ושיפוטית.
- מקורות: מגילת העצמאות, חקיקה, פסיקה.
- קול העם, ברגמן, שניצר, דנילוביץ - תקדימים מוקדמים.
- לא ניתן היה לפסול חוק מפורש, מלבד הפרת שריון.

פרק 9

זכויות מנויות ובלתי מנויות

9.1 הבעיה: מגילת זכויות חלקית

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו מגילת זכויות שלמה. הוא מונה זכויות מסוימות במפורש, אך זכויות חשובות כמו שוויון, חופש הביטוי, חופש הדת והזכות להליך הוגן אינן כתובות בו. השאלה המרכזית בפרק היא מה דינן של הזכויות האלה: האם הן נטולות הגנה חוקתית, או שניתן להגן עליהן בדרך אחרת? התשובה שהתקבלה בפסיקה היא ש"כבוד האדם" הוא זכות-אם שממנה נגזרות זכויות בלתי מנויות, אך רק בהיקף מסוים.

9.2 הזכויות המנויות

זכות	מקום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
חיים, גוף וכבוד	ס׳ 2 ו-4: אין פוגעים בהם, וכל אדם זכאי להגנה עליהם
קניין	ס׳ 3: אין פוגעים בקניינו של אדם
חירות אישית	ס׳ 5: אין נוטלים ואין מגבילים חירות במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת
יציאה מהארץ וכניסה אליה	ס׳ 6: חופש לצאת מישראל; אזרח זכאי להיכנס אליה
פרטיות וצנעת חיים	ס׳ 7: פרטיות, כניסה לרשות היחיד, חיפוש ופרטיות השיח

הזכויות האלה מוגנות בהגנה חוקתית ישירה, והגבלתן נבחנת בפסקת ההגבלה (ס׳ 8). החוק חל על כל רשות שלטונית (ס׳ 11). יש לשים לב שהחוק נוקט לשון "כל אדם" באשר הוא אדם, ולא רק אזרחים, ואילו חלק מהזכויות (כניסה לארץ) שמורות לאזרחים.

9.3 "כבוד האדם" כזכות-אם: שלושה דגמים

דגם	תוכן
מצמצם	רק ליבת הכבוד: השפלה וביזוי ממש
רחב (מקסימלי)	כמעט כל זכות אדם נגזרת מכבוד
ביניים (שהתקבל)	זכות בלתי מנויה נגזרת מכבוד כשהפגיעה בה קשורה בקשר ענייני והדוק לכבוד האדם

לפי דגם הביניים, שהוא הדגם המקובל, לא כל היבט של זכות נכנס. למשל, שוויון אינו מוגן חוקתית בכל היבט אלא כשהאפליה כרוכה בפגיעה בכבוד, בהשפלה או באוטונומיה. שתי תפיסות של "כבוד" משלימות זו את זו: **גישת האוטונומיה** (הנשיא ברק) רואה בליבת הכבוד את חופש הרצון והבחירה, ו**גישת ההשפלה** (השופטת דורנר) רואה אותה בהגנה מפני ביזוי ופגיעה בערך האנושי הבסיסי.

✦ הגדרה — זכות נגזרת

זכות שאינה כתובה בחוק היסוד, אך זוכה להגנה חוקתית כי היא קשורה בקשר ענייני הדוק לכבוד האדם. ההגנה חלה בהיקף הקשר, לא מעבר לו.

9.4 זכויות שהוכרו כנגזרות

- **שוויון** - במידה שהאפליה קשורה לכבוד (בעיקר מטעמי מין, לאום, גזע, נטייה מינית).
- **חופש הדת והחופש מדת** - בהקשרים של אוטונומיה ומצפון.
- **חופש הביטוי** - הזכות המרכזית של שיח דמוקרטי.
- **הזכות להליך הוגן** וגישה לערכאות - עיקרי ההליך המשפטי.
- **הזכות לחיי משפחה והורות** - נגזרת מהכבוד והאוטונומיה.
- **הזכות לקיום מינימלי בכבוד** - עיקרון חברתי (פרק 17).

⚖ פסק דין — עדאלה נ׳ שר הפנים (בג"ץ 7052/03, 2006)

בית המשפט דן בחוק האזרחות והכניסה (הוראת שעה) שמנע איחוד משפחות בין אזרחי ישראל לתושבי השטחים. נקבע שהזכות לחיי משפחה, ובכלל זה חיי משפחה בישראל, מוגנת כחלק מהכבוד, וכי הפגיעה בה נבחנת בפסקת ההגבלה. עם זאת, ברוב של שישה מול חמישה נדחו העתירות. ההלכה: הכרה בזכות נגזרת ובחינה מידתית, גם כשמובילה לדחיית העתירה.

⚖ פסק דין — צמח נ׳ שר הביטחון (בג"ץ 6055/95, 1999)

חוק השיפוט הצבאי אפשר לעצור חייל פרק זמן ממושך לפני שיובא בפני שופט. בית המשפט קבע שהחירות האישית (ס׳ 5) מחייבת פיקוח שיפוטי מהיר, והוראה הפוגעת בה בלי מידתיות אינה תקפה. ההלכה: זכות מנויה (חירות) מגנה מפני מעצר ממושך בלי שופט; ההגנה חלה גם על חיילים.

⚖ פסק דין — המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (הפרטת בתי הסוהר, 2009)

נקבע שהעברת סמכויות כפייה לגורם פרטי הפועל מתוך מניע רווח פוגעת בכבוד האסירים ובחירותם, וכי הפגיעה אינה מידתית. ההלכה: גם כבוד האדם המנוי (ולא רק הנגזר) יכול לחול על מאפיינים מבניים של ההליך הציבורי.

9.5 עיגון מלא או חלקי

הזכות הבלתי מנויה אינה נגזרת "במלואה" אלא רק בהיקף שבו הפגיעה קשורה לכבוד. כך, אפליה תעסוקתית רגילה שאין בה השפלה עשויה לא להיחשב פגיעה חוקתית בשוויון, ועדיין תהיה אסורה לפי דיני

העבודה. וגם: לא כל פגיעה בביטוי היא פגיעה חוקתית. זו הסיבה שבפסיקה ניתן לעיתים הדגש על אוטונומיה והשפלה, ומשום כך חשוב במבחן לנסח את הקשר לכבוד, ולא להסתפק בציון הזכות.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון ששוויון מנוי בחוק היסוד - הוא נגזרת בלבד.
- לטעון שכל זכות נגזרת מכבוד באופן מלא - ההגנה חלה בהיקף הקשר.
- לבלבל בין "כבוד" המנוי (ס׳ 2 ו-4) לבין "כבוד" כזכות-אם לנגזרות.
- להניח שזכות נגזרת אינה כפופה לפסקת ההגבלה - היא כפופה.

9.6 שלד לפתרון שאלה

1. זהה את הזכות: האם היא מנויה בחוק היסוד?
2. אם לא - האם יש קשר ענייני הדוק לכבוד האדם (דגם הביניים)?
3. קבע את היקף ההגנה: ליבה או היבט בלבד.
4. עבור לפסקת ההגבלה.
5. סכם: האם החוק או ההחלטה פוגעים בזכות באופן חוקתי?

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק מתיר לפטר עובדת בשל הריון בלבד. **פתרון:** שוויון אינו מנוי, אך אפליה מטעמי מין והריון משפילה ופוגעת בכבוד. לפי דגם הביניים היא נגזרת מכבוד האדם, ולכן הפגיעה נבחנת בפסקת ההגבלה (בחוק, תכלית ראויה, מידתיות), שבה ככל הנראה תיכשל.

9.7 תפיסות הכבוד ומשמעותן המעשית

ההבחנה בין גישת האוטונומיה לגישת ההשפלה אינה אקדמית בלבד. אם ליבת הכבוד היא אוטונומיה, יש הצדקה להגן על זכויות כמו חופש הביטוי וחיי משפחה כבחירה אישית. אם ליבתו היא הגנה מפני השפלה, ההגנה תיטה לאפליה ולפגיעות בערך האנושי. בפועל שתי הגישות מתלכדות ברוב המקרים. במבחן יש לציין איזו גישה מסבירה את התוצאה, ולהזכיר שדגם הביניים מחייב קשר ענייני הדוק, ולכן לא כל פגיעה בזכות נגזרת תהיה פגיעה חוקתית.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- מנויות: חיים, גוף, כבוד, קניין, חירות, יציאה וכניסה, פרטיות.
- בלתי מנויות נגזרות מכבוד האדם: שוויון, ביטוי, דת, הליך הוגן, חיי משפחה, קיום מינימלי.
- דגם הביניים: קשר ענייני הדוק.
- ההגנה בהיקף הקשר בלבד.

פרק 10

פסילת מפלגות

10.1 הבעיה: דמוקרטיה מתגוננת

פסילת מפלגות ורשימות מועמדים היא אחת הסוגיות הרגישות ביותר במשפט החוקתי. מצד אחד, הזכות לבחור ולהיבחר וחופש ההתאגדות הם יסוד הדמוקרטיה. מצד שני, קיים חשש שגורמים יעשו שימוש במנגנון הדמוקרטי כדי לשלול את הדמוקרטיה עצמה, וזהו "הפרדוקס הדמוקרטי". הפתרון המקובל בישראל הוא **דמוקרטיה מתגוננת**: הכנסת קבעה בחקיקה עילות מצומצמות לפסילה, אך הפסיקה מחילה אותן בזהירות רבה, כי פסילה מונעת מאזרחים לבחור ומפלגה להתמודד.

10.2 עקרון חוקיות המנהל וההתפתחות ההיסטורית

נקודת המוצא היא עקרון חוקיות המנהל: רשות שלטונית, כמו ועדת הבחירות המרכזית, רשאית לפעול רק מכוח הסמכה בחוק. השאלה הייתה מהיכן שואבת הוועדה את הכוח לפסול רשימה. ההתפתחות התבצעה בשלושה שלבים:

1. **ירדור (1965)** - ועדת הבחירות פסלה רשימה שאנשיה שללו את עצם קיום המדינה, בלי הסמכה מפורשת. בית המשפט אישר ברוב, בנימוק של הגנה עצמית של המדינה ו"נסיבות מיוחדות", ובכך התייחס לדמוקרטיה מתגוננת.
2. **ניימן (1985)** - ועדת הבחירות פסלה את "כך" ואת "הרשימה המתקדמת לשלום", אך בית המשפט ביטל את הפסילה והבהיר שנדרשת הסמכה מפורשת בחוק.
3. **חקיקת ס׳ 7א** - הכנסת חוקקה את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת (1985), המסמיך במפורש לפסול ומונה את העילות.

§ סעיף — ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת - עילות הפסילה

רשימת מועמדים, או מועמד, לא ישתתפו בבחירות אם יש במטרות או במעשים שלהם, במפורש או במשתמע: (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; (2) הסתה לגזענות; (3) תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. העילה השלישית נוספה בתיקון משנת 2002.

10.3 חוק המפלגות וסעיף 5

בשנת 1992 נחקק חוק המפלגות, שיצר את רשם המפלגות. ס׳ 5 לחוק מורה שלא תירשם מפלגה אם יש במטרותיה או במעשיה אחת העילות שבס׳ 7א, ובנוסף עילה רביעית: חשש סביר שהמפלגה תשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית. העילות זהות לאלה שבחוק היסוד, ולכן גם פרשנותן זהה. עם זאת, יש הסוברים שיש לפרש את ס׳ 5 בצמצום רב יותר, כי אי-רישום מפלגה חמור מאי-אישור השתתפותה בבחירות, שכן הוא פוגע בקיומה הפוליטי בשלב מוקדם.

	ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת	ס׳ 5 לחוק המפלגות
הגוף המכריע	ועדת הבחירות המרכזית, באישור בית המשפט העליון	רשם המפלגות
הנושא	אישור רשימה / מועמד לבחירות	רישום מפלגה
עילות	שלוש (מדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות, תמיכה בטרור)	אותן שלוש + מסווה לפעילות בלתי חוקית

10.4 הפרשנות המצמצמת: הלכת טיבי

בפרשת טיבי (2003) ביטל בית המשפט פסילות של מועמדים ורשימה על ידי ועדת הבחירות. נקבעה פרשנות מצמצמת ודבקנית, כדי למנוע את הפרדוקס הדמוקרטי. לפי ההלכה, "מדינה יהודית" כוללת בין היתר רוב יהודי, חגים ושבת, השפה העברית, ומורשת ישראל, ו"מדינה דמוקרטית" כוללת ריבונות העם

ובחירות, זכויות אדם, הפרדת רשויות ושלטון החוק. פסילה מחייבת שלילה של הליבה של ערכים אלה, ולא ביקורת עליהם.

⚖ פסק דין — טיבי (בחירות 2003)

ועדת הבחירות המרכזית פסלה את רשימת בל"ד ואת המועמדים עזמי בשארה ואחמד טיבי. בית המשפט העליון ביטל את הפסילה. נקבע שהעילות תפורשנה בצמצום, שנדרשות ראיות ברורות, משכנעות וחד-משמעיות, שהעילה צריכה להיות יעד מרכזי ולא שולי, ושיש לבחון אם המפלגה פועלת בפועל. בספק - מאשרים. ההלכה: פסילה היא צעד אחרון.

10.5 עקרונות מנחים לוועדה

- האם אחת העילות מתקיימת במטרות או במעשי המפלגה?
- האם העילה היא יעד מרכזי של המפלגה ולא עניין שולי וטפל?
- האם המפלגה פועלת בפועל, או שהיא מסתפקת בדיבורים?
- האם הראיות ברורות וחד-משמעיות ברמת ודאות גבוהה?
- בספק - מאשרים את ההשתתפות; פסילה היא חריג.

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

בשאלה על פסילה שמור על הסדר: מקור הסמכות (ס׳ 7א או ס׳ 5), העילה הרלוונטית, רמת הראיות (ברורה וחד-משמעית), ועקרון "בספק מאשרים". ציין שהפסילה חייבת אישור בית המשפט העליון.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שוועדת הבחירות רשאית לפסול כל מפלגה - נדרשת הסמכה ועילה.
- לבלבל בין עילות ס׳ 7א (שלוש) לעילות ס׳ 5 (ארבע).
- להניח שביקורת קשה על המדינה היא עילה - נדרשת שלילה של קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית.
- לשכוח שהסמכות מוטלת על הוועדה, אך הפסילה כפופה לאישור בג"ץ.

10.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהי המסגרת: בחירות (ס׳ 7א) או רישום (ס׳ 5)?
2. מהי העילה הנטענת?
3. מהן הראיות, האם הן ברורות וחד-משמעיות?
4. האם העילה מרכזית ופועלת בפועל?
5. מהי התוצאה: פסילה רק במקרים קיצוניים; בספק - אישור.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

רשימה מפרסמת מצע הקורא לשינוי חוקי הגירה ולהכרה בזכויות אוטונומיה למיעוט, ומבקרת בחריפות את אופי המדינה. **פתרון:** ביקורת חריפה וקריאה לשינוי חוקים אינן שלילת קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית. ללא ראיות מרכזיות וחד-משמעיות, אין עילת פסילה, ובספק מאשרים.

10.7 הליך הפסילה והסעדים

בבחירות לכנסת, ועדת הבחירות המרכזית מכריעה בבקשות לפסול רשימה או מועמד. כדי שהפסילה תיכנס לתוקף, נדרש אישור של בית המשפט העליון, והדיון נעשה בהרכב מורחב. אם הוועדה דחתה בקשת פסילה, ניתן לערער על כך לבית המשפט העליון. בית המשפט בוחן את החומר הראייתי בעצמו ואינו מסתפק בהכרעת הוועדה, שהיא גוף פוליטי. זו הסיבה לכך שההלכות המרכזיות בנושא מתגבשות בבית המשפט העליון, ולכך שאחוז הפסילות שאושרו נמוך בהרבה מאחוז הבקשות.

10.8 ירדור, ניימן וס׳ 7א: השוואה

	ירדור (1965)	ניימן (1985)	אחרי חקיקת ס׳ 7א
הסמכה מפורשת בחוק	אין	אין, ונקבע שנדרשת	קיימת בחוק היסוד
תוצאת הפסק	הפסילה אושרה	הפסילה בוטלה	עילות מוגדרות ומצומצמות
הנימוק המרכזי	הגנה עצמית של המדינה	עקרון חוקיות המנהל	חקיקה מפורשת של הכנסת
הלקח למבחן	דמוקרטיה מתגוננת גם בלי חוק	הסמכה בחוק אין בלי סמכות לפסול	פסילה רק בעילה, בראיות ובאישור בית המשפט העליון

ההשוואה מראה מעבר מגישה שבה בית המשפט מוכן להכיר בסמכות מתוך שיקולי הישרדות של המדינה, לגישה שבה הסמכות נגזרת מחקיקה מפורשת. ההיגיון הוא שהזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד, ואין פוגעים בה בלי הסמכה ברורה. חקיקת ס׳ 7א, בעקבות ניימן, סגרה את הפער שהפסיקה חשפה.

! שים לב — מלכודות נוספות

- להציג את ירדור כהלכה הנוהגת היום - ניימן וס׳ 7א שינו את המצב.
- לבלבל בין רמת הראיות (ברורות וחד-משמעיות) לבין מרכזיות העילה: אלה שני תנאים נפרדים, והם מצטברים.
- להסיק מהלכת טיבי שפסילה בלתי אפשרית - היא אפשרית כשהעילה מוכחת ברמה הנדרשת.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

ועדת הבחירות פסלה רשימה על בסיס נאום אחד של מועמד שולי, שבו הביע תמיכה בארגון טרור, בעוד מצע הרשימה ופעילותה נעדרים כל קשר לכך. **פתרון:** העילה (תמיכה במאבק מזוין) מופיעה רק באמירה בודדת, שאינה יעד מרכזי של הרשימה. לפי הלכת טיבי נדרשת עילה מרכזית וראיות חד-משמעיות, ובספק מאשרים. אפשר לשקול פסילה של המועמד עצמו, אך לא של הרשימה כולה, וכל החלטה טעונה אישור בית המשפט העליון.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- מקור הסמכות: ירדור, ניימן, ס׳ 7א.
- שלוש עילות; ס׳ 5 מוסיף מסווה לפעילות בלתי חוקית.
- הלכת טיבי: פרשנות מצמצמת, ראיות חד-משמעיות, צעד אחרון.
- בספק מאשרים.

פרק 11

חסינות חברי כנסת

11.1 מהי חסינות ולמה היא קיימת

חסינות היא הגנה מיוחדת שניתנת לחברי כנסת ומונעת נקיטת הליכים משפטיים נגדם בנסיבות מסוימות. תכליתה אינה להעניק זכות-יתר אישית לנבחר, אלא **להגן על עצמאות הרשות המחוקקת**: חבר כנסת צריך להיות מסוגל למלא את תפקידו, לבקר את הממשלה ולהצביע, בלי חשש מרדיפה משפטית או שלטונית. מכאן שהחסינות נמדדת לפי שיקול של תפקוד הפרלמנט, ולא לפי רצונו של חבר כנסת כזה או אחר. ההסדר מעוגן בחוק יסוד: הכנסת ובחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.

11.2 שני סוגי חסינות

	חסינות מהותית (עניינית)	חסינות דיונית (פרוצדורלית)
מה מוגן	פעולות ואמירות במילוי התפקיד	היעדר הליך פלילי בענייני חבר הכנסת
טיב ההגנה	מוחלטת; אינה ניתנת להסרה	יחסית; ניתנת להסרה, וצומצמה מאוד
היקף	אחריות פלילית ואזרחית	הליכים פליליים בלבד
מקור	ס׳ 1 לחוק החסינות	פרקים בחוק החסינות (כולל תיקון 29)

11.3 החסינות המהותית

ס׳ 1 לחוק החסינות קובע שחבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית בשל הצבעה, הבעת דעה או פעולה, בין בכנסת ובין מחוץ לה, **במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו**. זו הגנה חזקה על חופש הפעולה הפרלמנטרי. אי אפשר "לחסל" אותה בהחלטת הכנסת. לכן השאלה המרכזית היא: מתי פעולה נחשבת "במילוי התפקיד"?

✦ הגדרה — מבחני הזיקה לתפקיד (לפי הפסיקה)

נקבעו מבחני עזר לקביעת הזיקה. **מבחן הסיכון הטבעי** - האם הפעולה היא חלק מהסיכונים הטבעיים הכרוכים בתפקיד חבר כנסת. **מבחן הזיקה** - עד כמה הפעולה קשורה עניינית למילוי התפקיד. פעולה פלילית מובהקת, כמו לקיחת שוחד או זיוף, חורגת מכל סיכון טבעי ואינה מוגנת.

⚖ פסק דין — בשארה - גבולות הפעולה הפוליטית

נדונה השאלה אם אמירות פוליטיות מסוימות חוסות תחת החסינות המהותית. נקבע שגם לחסינות המהותית יש גבולות: אמירה שיש בה תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה או בארגון טרור חורגת מגדר מילוי תפקיד לגיטימי ואינה מוגנת. ההלכה: החסינות מגינה על שיח פוליטי לגיטימי, לא על כל אמירה. הכרטיס מציג את העיקרון הכללי ואינו מתאר את תוצאת ההליכים בפרשה.

11.4 החסינות הדיונית ותיקון 29

בעבר נהנו חברי כנסת מחסינות דיונית רחבה: כל העמדה לדין פלילי חייבה אישור הכנסת, ובפועל ההגנה הייתה כמעט אוטומטית. **תיקון 29** (2005) שינה את נקודת המוצא. כיום, ככלל, ניתן להעמיד חבר כנסת לדין בעבירה פלילית "רגילה" על ידי היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת רשאי לבקש מהכנסת להעניק לו חסינות מפני ההליך. הכנסת רשאית להעניק חסינות רק בעילות מצומצמות, למשל כשהמעשה נעשה במילוי התפקיד או כשיש חשש להעמדה לדין שנובעת משיקולים זרים או מהפליה. המגמה היא צמצום פערי המעמד בין חבר כנסת לאזרח בעבירות פליליות רגילות.

§ סעיף — נקודות לתיקון 29

נקודת המוצא: אין חסינות דיונית אוטומטית. הבקשה לחסינות מוגשת לכנסת. ההכרעה נעשית בדרך כלל ברוב חברי הכנסת בנוכחות הצדדים. העילות מצומצמות ואינן נוגעות להגנה על מעמד בלבד.

11.5 המתח בין חסינות לשוויון בפני החוק

מבקריה של החסינות טוענים שהיא פוגעת בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק, שכן נבחרי ציבור אינם צריכים לקבל הגנה שמעבר לאזרחים. התומכים טוענים שהיא הכרחית לתפקוד הפרלמנט, ושבלעדיה אפשר יהיה להשתמש בהליכים פליליים כנשק פוליטי נגד נבחרים. הפתרון בישראל מאזן ביניהם: חסינות מהותית רחבה, דיונית מצומצמת. הרעיון הוא שהמעשה שבתפקיד מוגן, וההליך הפלילי נגד העבירה הפרטית אינו מוגן.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לבלבל בין מהותית (על מילוי תפקיד) לדיונית (על ההליך).
- לטעון שהחסינות המהותית ניתנת להסרה - אינה ניתנת.
- לטעון שחבר כנסת חסין מפני כל הליך פלילי - אחרי תיקון 29 הוא מוגן רק בחסינות מצומצמת.
- להניח שכל אמירה פוליטית מוגנת - יש גבולות.

11.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהי הפעולה? אמירה, הצבעה או מעשה?
2. האם נעשתה במילוי התפקיד או למענו? החל מבחני הסיכון הטבעי והזיקה.

3. אם כן - חסינות מהותית: אין אחריות פלילית או אזרחית.
4. אם לא - חסינות דיונית: ניתן להעמיד לדין, וחבר הכנסת יכול לבקש חסינות בעילות מצומצמות.
5. בדוק אם המעשה פלילי מובהק, שחורג מהתפקיד.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חבר כנסת נאם בכנסת ובתקשורת נגד פקיד, ונתבע בלשון הרע. מנגד, אותו חבר כנסת נחשד בקבלת שוחד. **פתרון:** הנאום שבתפקיד מוגן בחסינות מהותית. השוחד אינו במילוי התפקיד, ולכן אין חסינות מהותית, ויש לבדוק רק אם הכנסת תעניק חסינות דיונית בעילות המצומצמות.

11.7 זכויות וחובות נוספות של חבר כנסת

חוק החסינות אינו עוסק רק בחסינות אלא גם בזכויות ובחובות של חברי הכנסת. מבחינת זכויות, חבר הכנסת זכאי לשכר ולהוצאות הדרושות למילוי תפקידו, ולחופש תנועה בתחומי הכנסת. מבחינת חובות, הוא כפוף לכללי אתיקה, לחובת דיווח על נכסים ולכללים בדבר ניגוד עניינים. תפקיד ועדת האתיקה של הכנסת הוא לפקח על ההתנהגות הזאת. הרעיון הוא שהחסינות אינה מנותקת מאחריות: ככל שהזכויות רחבות יותר, כך נדרשת ביקורת פנימית וציבורית חזקה יותר.

בבחינה על חסינות כדאי לציין שהחסינות המהותית חלה גם על מעשה שנעשה מחוץ לכנסת, כל עוד הוא במילוי התפקיד או למענו, כגון נאום בכנס ציבורי או הצהרה לתקשורת. לעומת זאת, מעשה שאינו קשור לתפקיד, כגון עבירה אישית, נבחן לפי הכללים הרגילים.

11.8 מקרים טיפוסיים: מהותית או דיונית

מעשה	חסינות מהותית?	הסבר

נאום במליאה נגד מדיניות הממשלה	כן	אמירה במילוי התפקיד
הצבעה בוועדת כנסת	כן	הצבעה היא פעולה מובהקת של התפקיד
ראיון בתקשורת על הצעת חוק קבלת שוחד	בדרך כלל כן	מחוץ לכנסת, אך למען מילוי התפקיד; נבחנת הזיקה
עבירה אישית ללא קשר לתפקיד	לא	עבירה פלילית מובהקת, החורגת מכל סיכון טבעי
	לא	נבחנת לפי ההליך הרגיל, ורק אז נשאלת שאלת החסינות הדיונית

בכל מקרה מהסוג הזה נשאלות שתי שאלות לפי הסדר. הראשונה: האם יש זיקה לתפקיד, כלומר האם חלה חסינות מהותית שפוטרת מאחריות. אם לא, השנייה: האם ניתן להעמיד לדין, והאם חבר הכנסת יכול לבקש מהכנסת חסינות דיונית בעילות המצומצמות. הסדר חשוב, כי חסינות מהותית שוללת את האחריות מעיקרה, ואילו חסינות דיונית רק דוחה או חוסמת את ההליך.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

חבר כנסת אמר במסיבת עיתונאים, בעניין הצעת חוק שהגיש, דברים שנטען כי הם לשון הרע כלפי בעל עסק. **פתרון:** החסינות המהותית חלה גם מחוץ לכנסת כשהפעולה היא למען מילוי התפקיד. דברים בעניין הצעת חוק קשורים לתפקיד ולכן מוגנים, בלי צורך בהחלטת הכנסת. אילו אמר דברים אישיים על שכנו בלי קשר לתפקיד, לא הייתה חלה עליהם חסינות מהותית.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- חסינות = הגנה על עצמאות הכנסת, לא זכות אישית.
- מהותית: מוחלטת, על מילוי תפקיד (ס׳ 1).
- דיונית: יחסית; תיקון 29 צמצם.
- מבחני סיכון טבעי וזיקה; עבירה פלילית מובהקת אינה מוגנת.

פרק 12

הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

12.1 עקרון השוויון

השוויון הוא מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי, והוא נוכח במגילת העצמאות ובפסיקה מראשית ימי המדינה. הגדרתו המדויקת אינה "יחס זהה לכולם" אלא **"יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים"**, לפי אמת מידה רלוונטית. לכן קיימת הבחנה בין **שוויון פורמלי** (יחס זהה טכני לכל) לבין **שוויון מהותי** (יחס המתחשב בהבדלים רלוונטיים ובנסיבות). הבחנה בין בני אדם מותרת כשהיא מבוססת על שוני רלוונטי למטרה, ואסורה כשהיא מבוססת על שיקול בלתי רלוונטי, ובראשם מין, גזע, לאום, דת ונטייה מינית.

✦ הגדרה — אפליה לעומת הבחנה מותרת

הבחנה מותרת: מבוססת על שוני רלוונטי למטרה (למשל גיל מינימלי לרישיון נהיגה). אפליה אסורה: מבוססת על שיקול בלתי רלוונטי, ובדרך כלל משפילה (למשל הדרה בשל מין). המבחן המרכזי הוא "השוני הרלוונטי".

12.2 המעמד החוקתי של השוויון

השוויון אינו מנוי במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הוא זכות בלתי מנויה, הנגזרת מכבוד האדם, אך רק בהיקף שבו האפליה כרוכה בהשפלה ובפגיעה באוטונומיה (דגם הביניים, פרק 9). אפליה משפילה היא פגיעה בכבוד ומקבלת הגנה חוקתית. מעבר לכך, השוויון מעוגן בחקיקה רגילה: חוק שוויון זכויות האישה (1951), חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1988) האוסר אפליה בקבלה לעבודה ובתנאיה, וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (1996). כך, גם אפליה שאינה חוצה את סף הכבוד אסורה על פי החוק.

12.3 העדפה מתקנת

לעיתים כדי להשיג שוויון מהותי מותר, ואף רצוי, להעדיף קבוצה שסבלה מאפליה היסטורית או מבנית, כגון ייצוג הולם של נשים או של מיעוטים בגופים ציבוריים. זו אינה "אפליה הפוכה" פסולה אלא כלי לתיקון אי-שוויון קיים. החוק מכיר בכך: בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות נקבעו הוראות המחייבות ייצוג הולם לקבוצות שונות, ובכלל זה נשים. ההעדפה כפופה למידתיות, כלומר היא צריכה להיות זמנית, לשרת תכלית ראויה של שוויון ולא לשלול לחלוטין את סיכוייהם של אחרים.

	שוויון פורמלי	שוויון מהותי	העדפה מתקנת
יסוד	יחס זהה לכל	יחס לפי הבדלים רלוונטיים	יחס מועדף לקבוצה מוחלשת
מטרה	אחידות	הוגנות בפועל	תיקון פער מבני
סיכון	התעלמות מפערים קיימים	הערכה שרירותית של "רלוונטיות"	פגיעה בשוויון הפרט

12.4 פסיקה מרכזית בנושא מין ונטייה מינית

⚖ פסק דין — אליס מילר נ׳ שר הביטחון (בג"ץ 4541/94, 1995)

אליס מילר, בעלת רישיון טיס אזרחי, ביקשה להיבחן לקורס טיס של חיל האוויר, אך נדחתה בשל היותה אישה. בית המשפט קבע שהדרת נשים מקורס הטיס מטעמי מין היא אפליה פסולה, ללא הצדקה מספקת, והורה לאפשר לה להיבחן. ההלכה: מין אינו שיקול רלוונטי להתאמה לתפקיד כשלעצמו, וההשלכות מוכרעות לפי כשירות אישית. הפסיקה פתחה בפני נשים תפקידים צבאיים נוספים.

⚖ פסק דין — אל-על נ׳ דנילוביץ (בג"ץ 721/94, פ"ד מח(5) 749)

אל-על העניקה כרטיסי טיסה בהנחה לבני זוג של עובדים, ושללה זאת מבן זוגו של דייל חד-מיני. בית המשפט קבע שזו אפליה אסורה מטעמי נטייה מינית, וחייב את אל-על להעניק את ההטבה. הסעד היה **הרחבת תחולה**: החלת ההסדר גם על הקבוצה שהוחרגה, במקום ביטול ההטבה לכולם.

⚖ פסק דין — נבו נ׳ בית הדין הארצי לעבודה (בג"ץ 104/87, 1990)

בתוכנית פנסיה נקבע גיל פרישה שונה לנשים ולגברים, וצעירה יותר לנשים. בית המשפט קבע שהבחנה כזו, גם כשהיא נראית "לטובת" נשים, מהווה אפליה פסולה בשל מין כאשר אינה מבוססת על שוני רלוונטי ומשמרת סטריאוטיפים. ההלכה: שוויון מחייב בחינה של הנחות יסוד סטריאוטיפיות.

⚖ פסק דין — שדולת הנשים (1994)

עתירה בנוגע לייצוג נשים בגופים ציבוריים ובמינויים. הפסיקה הדגישה את החובה לאפשר ייצוג הולם לנשים בגופים כאלה, כביטוי לשוויון מהותי. יש להסתפק בעיקרון.

12.5 הסעדים בהפליה

כשהבחנה נמצאת פסולה, קיימים שני סעדים עיקריים. האחד **ביטול ההטבה** לכולם, כדי לשוות מצב שווה. השני **הרחבת תחולה**, כלומר מתן ההטבה גם למי שהוחרג. בית המשפט נוטה להרחבה כשהמטרה היא להגן על זכות, ולביטול כשהמשאבים מוגבלים או כשההרחבה פוגעת בתכלית.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון ששוויון פירושו יחס זהה - הוא יחס שווה לשווים.
- לטעון ששוויון מנוי בחוק היסוד - הוא נגזרת בלבד.
- לחשוב שכל העדפה היא אפליה - העדפה מתקנת מותרת במידתיות.
- לבלבל בין הבחנה מותרת לאפליה: המפתח הוא שוני רלוונטי.

12.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהי ההבחנה שנעשתה, ובין מי למי?
2. האם קיים שוני רלוונטי למטרה? אם לא - אפליה.
3. האם האפליה משפילה, ולכן פוגעת בכבוד (הגנה חוקתית)?
4. אם כן - עבור לפסקת ההגבלה: חוק, ערכים, תכלית, מידתיות.
5. האם מדובר בהעדפה מתקנת? בדוק זמניות ומידתיות.
6. בחר סעד: ביטול או הרחבת תחולה.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חברה מציעה קורס הכשרה מיוחד רק לגברים בטענה שהתפקיד "פיזי". הנשים מוכנות לעמוד באותם תנאי כושר. **פתרון:** מין אינו שיקול רלוונטי כשלעצמו; הכשירות נבחנת אישית. יש אפליה פסולה (אליס מילר). הסעד: אפשרות להיבחן באותם מבחנים, ולא ביטול הקורס.

12.7 שוויון בין מגדרים: נקודות להרחבה

מעבר לפרשות שנסקרו, יש להכיר שני מושגים נוספים. **הפליה ישירה** היא הבחנה גלויה לפי מין. **הפליה עקיפה** היא קריטריון נייטרלי לכאורה שפוגע באופן לא מידתי בקבוצה אחת, כגון דרישת גובה שאינה קשורה לתפקיד אך פוסלת נשים רבות. בדיני העבודה נקבע שנטל ההוכחה עשוי לעבור למעסיק כשהעובדת מראה ראיה לכאורה להפליה. עוד חשוב: שוויון אינו נשמר רק בהתנהלות הרשות אלא גם בהסדרים פרטיים, ולכן מעסיקים פרטיים כפופים לאיסור ההפליה.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שוויון = יחס שווה לשווים ושונה לשונים לפי שוני רלוונטי.
- זכות בלתי מנויה, נגזרת מכבוד בהיקף אפליה משפילה; וגם בחקיקה רגילה.
- העדפה מתקנת מותרת במידתיות.
- אליס מילר, דנילוביץ, נבו: מין ונטייה מינית; סעד של הרחבת תחולה.

פרק 13

הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

13.1 האתגר: שוויון ולאום במדינה יהודית ודמוקרטית

אחת הסוגיות הרגישות ביותר במשפט החוקתי הישראלי היא אפליה על רקע לאום, גזע או מוצא. המתח נובע מכך שישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, והשאלה היא אם ואיפה מותר להבחין בין יהודים לבין אזרחים אחרים. התשובה בפסיקה: ההבחנה מותרת במקום שבו היא נגזרת מאופייה היהודי של המדינה ואינה פוגעת בזכויות יסוד, כגון בחוק השבות. אך היא אסורה בהקצאת משאבי ציבור (קרקע, תקציבים, שירותים) לאזרחים, שם חל עקרון השוויון במלואו.

✦ הגדרה — שוויון בהקצאת משאבי ציבור

המדינה, כנאמן הציבור, חייבת להקצות משאבי ציבור (כגון קרקע) ללא אפליה על בסיס לאום, דת או גזע. חובה זו חלה גם כשההקצאה נעשית באמצעות גוף שלישי הפועל מטעמה.

13.2 הלכת קעדאן

⚖ פסק דין — קעדאן נ׳ מינהל מקרקעי ישראל (בג"ץ 6698/95, פ"ד נד(1) 258, 2000)

משפחה ערבית, אזרחית ישראל, ביקשה לרכוש מגרש ביישוב קהילתי (קציר) שהוקם על קרקע מדינה. הבקשה נדחתה בשל השתייכותה הלאומית, שכן הקרקע הוקצתה באמצעות הסוכנות היהודית ליהודים בלבד. בית המשפט, מפי הנשיא ברק, קבע שהמדינה אינה רשאית להפלות על בסיס לאום בהקצאת קרקע ציבורית. עקרון השוויון חל על חלוקת משאבי המדינה גם באמצעות גוף מיישב. ההלכה: המדינה אינה יכולה "לעקוף" את חובת השוויון על ידי העברת ההקצאה לגוף שלישי, וגם לא על ידי הסדר של "נפרד אך שווה".

הטיעון המרכזי היה שהשוויון נגזר מערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. ייחודה היהודי של המדינה אינו מתיר להפלות אזרחים מיעוטים, שהרי מדינה דמוקרטית חייבת ליחס שווה לכל אזרחיה. מכאן ההבחנה: הכרה בייחוד היהודי בנושאים כמו עלייה, סמלי המדינה וחגים אינה אפליה, ואילו הדרה מהקצאת קרקע אסורה.

13.3 בשלות ואפקט מצנן

בסוגיות של אפליה מבנית עולה שאלת העיתוי של הביקורת השיפוטית. לפי **דוקטרינת הבשלות**, עתירה שהוגשה לפני שהאפליה התגבשה למעשה קונקרטי עלולה להידחות כלא בשלה. מנגד קיים החשש מ**אפקט מצנן**: דחייה על הסף עלולה להרתיע פנייה עתידית לבית המשפט ולחזק את הנורמה הפוגענית. בית המשפט נדרש לאזן בין השניים.

⚖ פסק דין — סבח נ׳ הכנסת (בג"ץ 2311/11, 2014)

נבחן חוק ועדות הקבלה ליישובים קהילתיים קטנים. טענת העותרים הייתה שהחוק מאפשר הדרה של ערבים ושל אוכלוסיות אחרות בשם "התאמה למרקם החברתי-תרבותי". בית המשפט דחה את העתירה כלא בשלה, כי החוק עצמו אוסר אפליה על רקע לאום, דת, מין ועוד, וטרם הוכח שהוא מופעל באופן פוגעני. ההלכה: ניתן לבקר בעתיד כשיתברר היישום בפועל, והבשלות היא תנאי להתערבות.

13.4 הגנות נוספות בחקיקה

- **חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (התשס"א)** - אוסר סירוב לספק שירות או להכניס לבית עסק בשל גזע, דת, לאום, מין, נטייה מינית ועוד.
- **חוק העונשין, ס׳ 144ב** - מעשה הסתה לגזענות הוא עבירה פלילית.
- **חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה** - אוסר אפליה בקבלה לעבודה, בין היתר על רקע לאום ודת.
- **חוקי תכנון ומקרקעין** - מחייבים הקצאה שוויונית ואוסרים הפליה על רקע לאום.

תחום	הבחנה מותרת	הבחנה אסורה
עלייה והגירה	חוק השבות מבחין בין יהודים ללא יהודים (נגזר מאופי המדינה)	הפליה בין אזרחים
משאבי ציבור	הקצאה לפי קריטריון ענייני ונייטרלי	הקצאה לפי לאום, דת או גזע
שירותי ציבור וחנויות	סירוב מטעמים עניינים	סירוב בשל גזע או לאום
הקצאת קרקע	קריטריונים נייטרליים	הקצאה ליהודים בלבד

13.5 קבוצות נוספות ואפליה מבנית

הדיון הציבורי והמשפטי עוסק גם באפליה על רקע מוצא (כגון יוצאי אתיופיה) ובהקצאת תקציבים שוויונית לרשויות ערביות. הכלי המשפטי המרכזי הוא עקרון השוויון בהקצאת משאבים, יחד עם חובת הנמקה ונתונים. בתחומים אלה ההוכחה קשה, כי האפליה מבנית ולא מוצהרת, ולכן מוצבים בפני בית המשפט שני מבחנים: האם יש הבדל רלוונטי בין הקבוצות, והאם הקריטריון הנייטרלי לכאורה גורם לתוצאה מפלה (אפליה עקיפה).

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שכל הבחנה בין יהודים לאחרים אסורה - חוק השבות מותר.
- לבלבל בין עלייה (מותרת) להקצאת משאבים (אסורה).
- לטעון שהסוכנות היהודית יכולה לעקוף את השוויון - לפי קעדאן אינה יכולה.
- לחשוב שבסבח נקבעה כשרות החוק לצמיתות - נקבע שאין בשלות.

13.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהי הקבוצה והאם ההבחנה היא על בסיס לאום, דת או גזע?
2. האם מדובר בהקצאת משאב ציבורי (קרקע, תקציב) או בעלייה ומעמד?
3. האם יש שוני רלוונטי? אם לא, אפליה.
4. האם ההקצאה נעשית באמצעות גוף שלישי? לפי קעדאן אין הבדל.
5. בחן בשלות, ובחר סעד.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

מועצה מקומית מקצה קרקע ביישום שהוקם בתמיכת המדינה רק למי שעבר שירות צבאי, והדבר מוציא כמעט את כל האוכלוסייה הערבית. **פתרון:** זו אפליה עקיפה: קריטריון נייטרלי לכאורה גורם לתוצאה מפלה. יש לבחון אם יש הצדקה ענייינית רלוונטית ומידתית; ללא הצדקה, ההקצאה פסולה לפי עקרון קעדאן.

13.7 סוגיות מתקדמות בשוויון על רקע לאום

בבחינת שאלות על שוויון לאומי יש להבחין בין שלושה שלבים. השלב הראשון הוא קביעה אם יש הבחנה, ישירה או עקיפה. השלב השני הוא בדיקת הרלוונטיות: האם הבחנה קשורה למטרה לגיטימית, למשל ביטחון, או שהיא מסווה אפליה. השלב השלישי הוא הסעד, שיכול לכלול ביטול ההחלטה, הקצאה שוויונית מחדש, או הוראה לבחון מחדש. עקרון חשוב נוסף הוא חובת הנימוק: כאשר רשות מקצה משאב ציבורי לקבוצה אחת, עליה להסביר את הקריטריון ולהוכיח שהוא נייטרלי.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- קעדאן: אסור להפלות בהקצאת קרקע ציבורית על רקע לאום.
- המדינה אינה יכולה לעקוף שוויון באמצעות גוף שלישי.
- סבח: בשלות; ועדות קבלה.
- חוק השבות מותר; הקצאת משאבים לאזרחים חייבת בשוויון.

פרק 14

חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

14.1 מקומו של חופש הביטוי

חופש הביטוי הוא אחת הזכויות המרכזיות במשטר דמוקרטי. הוא אינו מנוי במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובכל זאת הוא מוכר כזכות יסוד בעלת מעמד רם. הכרה זו קדמה לחוקי היסוד של 1992 והתבססה על פסיקה, ובראשה פסק הדין **קול העם** משנת 1953. בפרק זה נעסוק ביסודות הזכות ובהלכת קול העם. בפרק הבא נעסוק במעמדה החוקתי ובאיזונים מול זכויות ואינטרסים אחרים.

14.2 שלושת הרציונלים לחופש הביטוי

רציונל	תוכן
חיפוש האמת (שוק הרעיונות)	בתחרות חופשית בין רעיונות האמת תצא לאור
קיום ההליך הדמוקרטי	בחירה מושכלת וביקורת על השלטון דורשות מידע ודעות חופשיים
מימוש עצמי	ביטוי הוא חלק מהאוטונומיה ומהכבוד של הפרט

שלושת הרציונלים משלימים זה את זה ומסבירים מדוע מעמדו של חופש הביטוי גבוה. בדרך כלל ביטוי פוליטי הוא בעל ההגנה החזקה ביותר, כי הוא קרוב ביותר לרציונל הדמוקרטי. ביטוי מסחרי, או ביטוי שאין לו ערך ציבורי, יזכה להגנה, אך לרוב חלשה יותר.

14.3 הלכת קול העם

⚖ פסק דין — קול העם נ׳ שר הפנים (בג"ץ 73/53, פ"ד ז 871, 1953)

שר הפנים סגר זמנית שני עיתונים, "קול העם" ו"אל-אתיחאד", בטענה שמאמרים בהם, שבקרו חריפות את מדיניות הממשלה, מסכנים את שלום הציבור. הסמכות נשענה על פקודת העיתונות, שאפשרה לשר לסגור עיתון אם פרסומו עלול לסכן את שלום הציבור. בית המשפט, מפי השופט אגרנט, ביטל את הסגירה. נקבע שחופש הביטוי הוא יסוד המשטר הדמוקרטי, ושיש לפרש בצמצום סמכות שמגבילה אותו. הוא קבע את מבחן **הוודאות הקרובה**: אפשר להגביל ביטוי רק אם קיימת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור, ולא די בחשש או בנטייה כללית.

ההלכה ביצעה איזון בין שני ערכים: חופש הביטוי מול שלום הציבור. בחירת מבחן הוודאות הקרובה, ולא מבחן רופף של "נטייה לפגיעה", פירושה ששלום הציבור אינו יכול להצדיק הגבלה בכל חשש. הדגש הוא על הסתברות גבוהה ועל נזק ממשי. מבחן זה הפך לאבן יסוד, והורחב בהמשך למקרים נוספים.

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

כשנשאלים על קול העם, כתוב: (1) העובדות בקצרה; (2) הקביעה שחופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה; (3) פרשנות מצמצמת לסמכות המגבילה; (4) מבחן הוודאות הקרובה; (5) הערה שההלכה ניתנה לפני העיגון החוקתי.

14.4 הרחבת ההלכה: ביטחון, רגשות ותחומים נוספים

⚖ פסק דין — שניצר נ׳ הצנזור הצבאי הראשי (בג"ץ 680/88, 1989)

הצנזור פסל פרסום מאמר עיתונאי בנושא ביטחוני. בית המשפט החיל את מבחן הוודאות הקרובה גם בענייני ביטחון, ופסל את שיקול הדעת הרחב של הצנזור. ההלכה: חופש הביטוי גובר, אלא אם קיימת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון. נקבע שלא די בחשש רחוק.

⚖ פסק דין — לאור נ׳ מועצת הסרטים והמחזות (בג"ץ 14/86, 1987)

נדונה סמכות מועצה לאסור הצגת יצירה בטענה לפגיעה ברגשות הציבור. בית המשפט החיל מבחן קרוב לוודאות קרובה גם על פגיעה ברגשות, ודרש פגיעה חמורה וקרובה. יש להסתמך על העיקרון.

14.5 הגבלות מקובלות על חופש הביטוי

- **שלום הציבור וביטחון המדינה** - לפי מבחן הוודאות הקרובה.
- **הסתה לגזענות** (ס׳ 144ב לחוק העונשין) והסתה לאלימות או לטרור.
- **לשון הרע** - הגנה על שם טוב (נדון בפרק הבא).
- **פרטיות** - איזון בין ביטוי לפרטיות.
- **בזיון בית משפט**, גילוי סודות מדינה והגנה על ההליך השיפוטי.
- **תוכן גס ופורנוגרפיה** - בכפוף למידתיות.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שקול העם ניתנה לאחר המהפכה החוקתית - ניתנה ב-1953.
- לטעון שמבחן הוודאות הקרובה מקל על הגבלת ביטוי - הוא מקשה.
- לחשוב שביטוי פוגעני אינו מוגן - הוא מוגן ודווקא הוא זקוק להגנה.
- לבלבל בין שלום הציבור לבין רגשות הציבור: הראשון חמור יותר.

14.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהו הביטוי, ומי מגביל אותו (חוק, רשות, שר)?
2. האם יש הסמכה מפורשת? פרש בצמצום.
3. איזה ערך נוגד: שלום הציבור, ביטחון, שם טוב, פרטיות?
4. החל מבחן הוודאות הקרובה (או איזון אחר) ובדוק ודאות ונזק.
5. סכם: האם ההגבלה מידתית, והאם הביטוי הוא פוליטי.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

רשות מנעה הפגנה בטענה שהיא עלולה לעורר מתח. המארגנים הצהירו שההפגנה שלווה. **פתרון:** מתח כללי אינו ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. לפי קול העם, אין לאסור; אפשר לכל היותר להטיל תנאים שימנעו סיכון קונקרטי.

14.7 הבחנות נוספות בתחום הביטוי

חופש הביטוי כולל כמה צורות: **ביטוי מילולי** (נאום, כתיבה), **ביטוי סמלי** (דגל, הפגנה) ו**ביטוי אמנותי** (סרט, מחזה, ספר). הזכות כוללת גם את חופש המידע והזכות לקבל מידע, ואת הזכות שלא להתבטא. בדרך כלל ביטוי פוליטי יזכה להגנה חזקה יותר מביטוי מסחרי. עוד כלל: הגבלה על תוכן הביטוי חמורה

יותר מהגבלה על זמן ומקום, כי היא מכוונת אל המסר. כך, הגבלת הפגנה לשעות מסוימות היא קלה יותר מאיסור על הפגנה בגלל מה שהמפגינים אומרים.

לבסוף, נשאלת השאלה על ביטוי של רשויות השלטון עצמן. לרשות יש חופש ביטוי מוגבל, והיא מחויבת בהגינות ובאובייקטיביות כשהיא מדברת בשם הציבור.

14.8 מבחן הוודאות הקרובה ופסקי הדין המרכזיים

מבחן הוודאות הקרובה משלב שני צירים: הסתברות גבוהה להתממשות הנזק, וחומרת הנזק, שחייב להיות ממשי ולא קל. חשש כללי, נטייה לפגיעה או מתח ציבורי אינם עומדים בו. המבחן הופך את ברירת המחדל לטובת הביטוי: הרשות היא שצריכה להוכיח את הצורך בהגבלה.

	קול העם (1953)	שניצר (1989)
הגורם המגביל	שר הפנים, בסגירת עיתון	הצנזור הצבאי הראשי
הערך הנוגד	שלום הציבור	ביטחון המדינה
המבחן	ודאות קרובה לפגיעה ממשית	אותו מבחן, גם בענייני ביטחון
הלקח	פרשנות מצמצמת של סמכות מגבילה	שיקול דעת רחב של רשות אינו מספיק

! שים לב — מלכודות בהחלת המבחן

- לבלבל בין ודאות קרובה (מבחן מחמיר המגן על הביטוי) לבין חשש סביר או נטייה (מבחנים רפויים).
- לטעון שהמבחן חל רק על עיתונות - הוא הורחב גם לענייני ביטחון.
- לשכוח שהגבלת ביטוי טעונה הסמכה בחוק, ולא רק שיקול דעת של רשות.
- לטעון שהמבחן שולל כל הגבלה - הגבלה מותרת כשהוודאות הקרובה והנזק הממשי מוכחים.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

שר סגר עיתון בטענה שמאמר ביקורתי עלול "לעורר חוסר שקט" בציבור. **פתרון:** חוסר שקט כללי הוא חשש בלבד ולא ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. לפי קול העם סמכות הסגירה מפורשת בצמצום, ולכן אין להצדיק את הסגירה. כדי להצדיק הגבלה יש להראות הסתברות גבוהה לנזק ממשי, ולא להסתפק בחשש.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שלושה רציונלים: אמת, דמוקרטיה, מימוש עצמי.
- קול העם 1953: הוודאות הקרובה.
- שניצר: ביטחון; לאור: רגשות.
- ביטוי פוגעני מוגן; הגבלות לפי איזון ומידתיות.

פרק 15

חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

15.1 המעמד החוקתי של חופש הביטוי

חופש הביטוי אינו מנוי במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בפסיקה הוא מוכר כזכות יסוד, והדעה הרווחת היא שהוא **נגזר מכבוד האדם**, בשל הקשר ההדוק בין ביטוי לאוטונומיה ולמימוש עצמי. המשמעות המעשית היא שפגיעה בו בחקיקה נבחנת לפי פסקת ההגבלה (בחוק, תכלית ראויה, מידתיות), והכנסת אינה יכולה לפגוע בו בחוק רגיל שאינו עומד במבחנים אלה. עם זאת, הזכות אינה מוחלטת, והיא נתונה לאיזון מול אינטרסים אחרים.

15.2 נוסחאות איזון

סוג איזון	בין מי למי	דוגמה
איזון אנכי	זכות הפרט מול אינטרס ציבורי	ביטוי מול שלום הציבור וביטחון (קול העם)
איזון אופקי	שתי זכויות שוות מעמד	ביטוי מול שם טוב או פרטיות

בשני סוגי האיזון נבחנים הערך שבו נפגע, חומרת הפגיעה, והאפשרות להגן על שני הערכים גם יחד. ככל שהפגיעה קרובה יותר לליבת הזכות, כגון ביקורת פוליטית, נדרשת הצדקה חזקה יותר. ככל שהביטוי מרוחק מהליבה, כמו לשון הרע על עניין פרטי, ההגנה נחלשת.

15.3 ביטוי ושם טוב: דיני לשון הרע

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, מגן על שמו הטוב של אדם. הוא קובע את עוולת לשון הרע ואת הסייגים שלה. בין ההגנות: **אמת דיברתי** בצירוף עניין ציבורי, **תום לב** במסגרת ההגנות שבחוק, והגנת **הפרסום הסביר**. השאלה החוקתית היא כיצד לפרש את ההגנות באופן שיאזן בין השם הטוב, שגם הוא נגזר מהכבוד, לבין חופש הביטוי. הפסיקה נוטה לפרש את ההגנות ברוחב כשמדובר בעניינים ציבוריים וביקורת על נבחרים.

⚖ פסק דין — אבנרי נ׳ שפירא (ע"א 214/89, פ"ד מג(3) 840, 1989)

בית המשפט דן בהגנות בחוק לשון הרע ביחס לפרסום עיתונאי. הוא איזן בין חופש הביטוי לשם הטוב, והדגיש שבפרשנות החוק יש להעניק משקל לחופש העיתונות ולתפקידו בדמוקרטיה. ההלכה: חופש הביטוי משפיע על פרשנות סייגי החוק, אך אינו מבטל את הגנת השם הטוב.

15.4 הסתה, גזענות וביטוי פוגעני

ס׳ 144ב לחוק העונשין קובע עבירה של פרסום דברי הסתה לגזענות. כאן האיזון מוכרע לרוב לטובת ההגבלה, כי הביטוי פוגע בכבוד של קבוצות ובערכי הדמוקרטיה. עם זאת, גם בנושא זה נדרשת ליבה מוגדרת: נדרשת כוונה או אפשרות לפגיעה, ואין לאסור ביקורת לגיטימית. כלל נוסף: ביטוי פוגעני או מקומם, שאינו מסית, מוגן, כי ההגנה על דעות פופולריות אינה נדרשת.

15.5 הגבלה מראש והגבלה בדיעבד

הגבלה מראש (כגון צו איסור פרסום או צנזורה) חמורה יותר מ**אחריות בדיעבד** (כגון תביעת לשון הרע), כי היא מונעת את הביטוי מלכתחילה. לכן הגבלה מראש תותר רק במקרים קיצוניים, לפי מבחן הוודאות הקרובה. בדיעבד בית המשפט נוטה להקל, כי הנזק כבר קרה ואפשר להעמיד לדין או לפצות.

⚖ פסק דין — שניצר נ׳ הצנזור הצבאי הראשי (1989)

הצנזור פסל פרסום מאמר ביטחוני. נקבע שגם בעניין ביטחוני נדרשת ודאות קרובה לפגיעה ממשית, והשיקול של הצנזור כפוף לביקורת שיפוטית. ההלכה: הגבלה מראש דורשת הצדקה כבדה.

15.6 שלד לפתרון שאלה

1. איזה סוג ביטוי: פוליטי, אמנותי, מסחרי, פוגעני?
2. מהי ההגבלה: חוק, רשות, מראש או בדיעבד?
3. מהו הערך הנוגד: שלום הציבור, ביטחון, שם טוב, פרטיות, רגשות?
4. סוג האיזון: אנכי או אופקי.
5. החל פסקת הגבלה: חוק, תכלית, מידתיות; ובחר סעד.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שחופש הביטוי מוחלט.
- לטעון שאין הבדל בין הגבלה מראש לבדיעבד.
- לבלבל בין איזון אנכי לאופקי.
- לשכוח שגם שם טוב נגזר מכבוד ולכן הוא זכות שווה מעמד.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

עיתון פירסם כתבה על חבר מועצה, הכוללת עובדות שנבדקו חלקית. חבר המועצה תובע. **פתרון:** איזון אופקי בין ביטוי לשם טוב. בעניין ציבורי, בית המשפט יבחן את הגנת הפרסום הסביר ואת מידת הבדיקה שנעשתה; בדיקה חלקית מלמדת על רשלנות, ואז ההגנה עלולה שלא לחול.

15.7 הבחנה בין סוגי ביטוי ושאלות פתוחות

בשיח החוקתי נבחנת השאלה אם יש היררכיה בין סוגי ביטוי. המקובל הוא שביטוי פוליטי ואמנותי ממוקם בליבת ההגנה, וביטוי מסחרי בפריפריה. עם זאת, גם פרסומת עשויה להיות מוגנת, כל עוד אינה מטעה. עוד שאלה פתוחה היא האיזון מול פרטיות בעידן הדיגיטלי, שבו מידע ניתן להפצה מהירה ובלתי הפיכה.

בית המשפט נוטה לאזן בין התועלת הציבורית בפרסום לבין הפגיעה בפרט, ולהביא בחשבון את מעמדו של הנפגע: איש ציבור צפוי לסבול ביקורת רחבה יותר מאדם פרטי.

בשאלות מבחן על ביטוי ושם טוב מומלץ לציין את הגנות החוק, את משקל העניין הציבורי ואת מעמד הנפגע, ולהסביר מדוע הפגיעה נבחנת בפסקת ההגבלה.

15.8 עוצמת ההגנה לפי סוג הביטוי

סוג ביטוי	עוצמת ההגנה	הסבר
ביקורת פוליטית	חזקה ביותר	קרובה ביותר לרציונל הדמוקרטי
ביטוי אמנותי	חזקה	חלק מהאוטונומיה והמימוש העצמי
פרסומת מסחרית	מוגנת, אך חלשה יותר	בתנאי שאינה מטעה
לשון הרע בעניין פרטי	חלשה	מוכרעת באיזון אופקי מול שם טוב
הסתה לגזענות	ניתנת להגבלה	ס׳ 144ב לחוק העונשין

	הגבלה מראש	אחריות בדיעבד
דוגמאות	צו איסור פרסום, צנזורה	תביעת לשון הרע, העמדה לדין
מועד הפגיעה	לפני הביטוי	אחרי הביטוי
חומרה	חמורה יותר, מונעת את הביטוי	קלה יותר
המבחן	ודאות קרובה, במקרים קיצוניים	איזון לפי פסקת ההגבלה

! שים לב — מלכודות נוספות

- להסתפק בהגנת האמת: נדרש גם עניין ציבורי בפרסום.
- לטעון שהגבלה בדיעבד אינה נבחנת בפסקת ההגבלה - היא נבחנת.
- לבלבל בין ביטוי פוגעני, שהוא מוגן, לבין הסתה לגזענות, שניתנת להגבלה.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

עיתון פירסם כי חבר כנסת קיבל טובת הנאה, על סמך מקור אחד שלא נבדק. **פתרון:** זהו איזון אופקי בין ביטוי לשם טוב. אם האמת לא הוכחה, נבחנת הגנת הפרסום הסביר, ובדיקה בלתי מספקת של מקור יחיד מערערת אותה. העניין הציבורי ומעמדו של הנפגע כנבחר ציבור מרחיבים את ההגנה על הביטוי, אך אינם פוטרים מחובת בדיקה.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- חופש הביטוי נגזר מכבוד והוא כפוף לפסקת ההגבלה.
- איזון אנכי מול אינטרס ציבורי; אופקי מול זכות.
- לשון הרע: איזון בין שם טוב לביטוי.
- הגבלה מראש חמורה מבדיעבד; הסתה לגזענות מותרת להגבלה.

פרק 16

חופש הדת והחופש מדת

16.1 שני צדדים של הזכות

חופש הדת הוא הזכות להאמין ולקיים פולחן ומצוות לפי אמונתו של אדם, ללא כפייה והפליה. **החופש מדת** הוא הצד המשלים: הזכות שלא לכפות על אדם נורמה דתית שאינה שלו. שתי הזכויות אינן מנויות במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והפסיקה רואה בהן נגזרות מכבוד האדם והאוטונומיה, וכפופות לפסקת ההגבלה. הנושא רגיש במיוחד בישראל, בשל היותה מדינה יהודית ודמוקרטית שבה יש הסדרים רבים של דת ומדינה.

✦ הגדרה — צדק פנימי מול חיצוני

הצדקה פנימית להגבלה נובעת מהדת עצמה (כגון חובה הלכתית). הצדקה חיצונית נובעת מהמדינה וממערכת ערכים אזרחית (כגון סדר ציבורי, רגשות, מורשת). בית המשפט מעדיף הצדקות חיצוניות, ומאזן בין זכויות.

16.2 מרחב ההסדרים של דת ומדינה

תחום	הסדר	משמעות חוקתית
נישואין וגירושין	חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953: יהודים לפי דין תורה	אין נישואים אזרחיים; פגיעה אפשרית בחופש מדת
שבת	חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951: יום המנוחה השבועי	איזון בין דת לחופש עיסוק
חזיר	חוק איסור גידול חזיר, התשכ"ב-1962	פגיעה בעיסוק; איזון בין דת וחופש

רשויות מקומיות	חוקי עזר לעניין מכירת בשר לא כשר	הצורך לאזן בין אופי היישוב לזכויות

בנישואין, הפתרון המעשי שהתפתח הוא שרישום נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל מתקבל במרשם האוכלוסין. הדבר נקבע בפרשת פונק-שלזינגר (1963), שבה נקבע שפקיד הרישום אינו בוחן את תוקף הנישואין אלא רק רושם את עובדת הנישואין, בלי להכיר בהם כתקפים לכל דבר. כך הושג איזון חלקי בין החוק הדתי לבין חופש מדת.

16.3 הלכת חורב: דת מול חופש התנועה

⚖ פסק דין — חורב נ׳ שר התחבורה (בג"ץ 5016/96, פ"ד נא(4) 1, 1997)

הוחלט לסגור לתנועת כלי רכב בשבת, בשעות התפילה, את רחוב בר-אילן בירושלים, כי התנועה פוגעת ברגשותיהם הדתיים ובקדושת השבת בשכונות סמוכות. מנגד נטען שהסגירה פוגעת בחופש התנועה של תושבים אחרים. בית המשפט הכיר בפגיעה ברגשות דתיים כאינטרס שיכול להצדיק הגבלה, אך קבע שהפגיעה חייבת להיות **חמורה, קשה ורצינית**, ושיש לבחון מידתיות. בפועל בוטלה החלטת הסגירה והוחזרה לשר, בעיקר מפני שלא ניתן משקל מספיק לתושבים החילוניים שגרים ברחוב.

16.4 הלכת סולודקין: בשר חזיר והרשות המקומית

⚖ פסק דין — סולודקין נ׳ עיריית בית שמש (בג"ץ 953/01, 2004)

עיריית בית שמש חוקקה חוקי עזר המגבילים מכירת בשר חזיר. התושבים הטילו ספק בסמכות ובמידתיות. בית המשפט קבע שלרשות מקומית סמכות להגביל, כי נושא זה נכלל בסמכויות העירייה, אך עליה לאזן בין אופי השכונה והעיר לבין חופש העיסוק וחופש מדת. נקבע שבאזורים בעלי אופי דתי מובהק אפשר להגביל יותר, ובאזורים מעורבים או חילוניים יש להקל. ההלכה: מידתיות לפי נסיבות מקומיות.

16.5 איזון בין דת למדינה

הקושי המרכזי הוא שהגבלות מטעמי דת עלולות לפגוע בזכויות של מי שאינו מקיים את הדת (חופש מדת, תנועה, עיסוק, שוויון). בית המשפט משתמש בכמה כלים: (1) דורש פגיעה חמורה ברגשות הדתיים, ולא פגיעה קלה; (2) מחיל מידתיות ובוחן חלופות פחות פוגעות כמו הגבלת שעות או אזורים; (3) מעדיף פתרונות של ויתור הדדי; (4) בוחן אם ההגבלה נעשתה בחקיקה ראשית או בהסמכה מפורשת.

- פגיעה ברגשות דתיים כשלעצמה אינה מצדיקה הגבלה גורפת.
- נדרשת פגיעה חמורה, קשה ורצינית, בנסיבות ברורות.
- יש להעדיף אמצעי מצומצם: הגבלת זמן או מקום.
- בשאלות של אופי יישוב, ניתן להבחין בין אזורים שונים.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שחופש הדת מנוי בחוק היסוד - אינו מנוי.
- לטעון שרגשות דתיים מצדיקים כל הגבלה - לא.
- לבלבל בין חופש הדת לחופש מדת.
- להניח שבחורב נסגר הרחוב לחלוטין - הפתרון היה חלקי.

16.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהי הזכות: חופש דת או חופש מדת? מהו הצד הנפגע?
2. מהו האינטרס הנוגד: רגשות דתיים, תנועה, עיסוק?
3. האם הפגיעה חמורה, קשה ורצינית?
4. האם קיימת הסמכה בחוק? מהי החלופה הפחות פוגעת?
5. סכם: איזון לפי מידתיות, ובחר פתרון (הגבלת זמן או מקום).

✎ דוגמה — תרגיל פתור

עירייה אסרה מכירת בשר לא כשר בכל תחומיה, כולל שכונות חילוניות. **פתרון:** לעירייה סמכות להגביל (סולודקין), אך איסור גורף בכל העיר אינו מידתי כשיש אזורים מעורבים וחילוניים. יש להתאים את ההגבלה לאופי האזור, ולכן האיסור הגורף ייפסל.

16.7 חופש הדת בפרקטיקה: תחומים נוספים

מעבר לפרשות המרכזיות, השאלות של דת ומדינה מתעוררות גם בנושאי קבורה, גיוס, חינוך וכשרות. בכל התחומים האלה בית המשפט מבקש להימנע מכפייה דתית על מי שאינו מאמין, אך גם לכבד את זכויות הדתיים. אחד העקרונות המנחים הוא שהמדינה אינה נדרשת להפריד לחלוטין בין דת למדינה, כי היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אך היא נדרשת לנהוג בסובלנות ולהימנע מפגיעה מעבר לנדרש. כשמדובר בקבוצות מיעוט דתיות (מוסלמים, נוצרים, דרוזים), נשמר עיקרון שוויון בחופש הפולחן.

בבחינה, מומלץ לשרטט את שתי הזכויות ולבדוק מי נפגע, מהי חומרת הפגיעה, האם ההגבלה מבוססת בחוק, והאם ניתן להגיע לפשרה.

16.8 חורב וסולודקין: השוואה

	חורב (1997)	סולודקין (2004)

הגורם המגביל	החלטה על סגירת רחוב בשבת	חוקי עזר של רשות מקומית
האינטרס הדתי	רגשות דתיים וקדושת השבת	אופי היישוב ורגשות דתיים
הזכות הנגדית	חופש התנועה	חופש עיסוק וחופש מדת
התוצאה	בוטלה החלטת הסגירה בשעות התפילה והוחזרה לשר	סמכות להגביל, בכפוף למידתיות לפי אופי האזור

שני פסקי הדין מדגימים את אותה שיטה. לא נשאל רק אם יש פגיעה ברגשות דתיים, אלא כמה חמורה היא, מהי החלופה הפחות פוגעת ומהו ההקשר המקומי. לכן ההגבלה מותאמת לזמן, למקום ולאופי האזור, ולא נקבעת בגורף.

! שים לב — מלכודות נוספות

- לטעון שבחורב נקבע שרגשות דתיים אינם שיקול - נקבע שהם שיקול, בתנאי שהפגיעה חמורה.
- לטעון שלרשות מקומית אין סמכות להגביל בשר חזיר - סולודקין הכיר בסמכות.
- להחיל אותה הגבלה בכל אזור - סולודקין מבחין לפי אופי האזור.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

תושבים ביקשו לסגור רחוב ראשי בשבת לאורך כל שעות היממה, ללא חלופה לתושבים אחרים. **פתרון:** לפי חורב נדרשת פגיעה חמורה, קשה ורצינית ברגשות הדתיים. גם אם היא קיימת, סגירה מלאה ללא חלופה לתושבים אחרים פוגעת בחופש התנועה ובאינטרסים של התושבים הנוספים, ולכן סביר שלא תיחשב מידתית.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- חופש הדת וחופש מדת נגזרים מכבוד האדם.
- הסדרי דת ומדינה: נישואין, שבת, חזיר, כשרות.
- חורב: פגיעה חמורה ברגשות, מידתיות, התחשבות בתושבים החילוניים.
- סולודקין: סמכות רשות מקומית, איזון לפי אזור.

פרק 17

זכויות חברתיות

17.1 זכויות חברתיות והסוגיה החוקתית

זכויות חברתיות הן זכויות כלכליות וחברתיות כגון זכות לדיור, לחינוך, לבריאות, לביטחון סוציאלי ולקיום מינימלי. בניגוד לזכויות האזרחיות והפוליטיות (ביטוי, דת, חירות), שהן בדרך כלל זכויות "שליליות" המחייבות את המדינה להימנע מפגיעה, הזכויות החברתיות הן לרוב זכויות "חיוביות" המחייבות את המדינה לפעול, להקצות תקציב ולתת שירות. זו הסיבה לקושי החוקתי: הכרעות בנושא כרוכות בהקצאת משאבים, תחום המסור לרשויות הנבחרות, והן מעוררות את שאלת הפרדת הרשויות.

	זכויות אזרחיות ופוליטיות	זכויות חברתיות
אופי	שליליות: הימנעות מפגיעה	חיוביות: חובה לספק שירות
עלות	נמוכה יחסית	גבוהה, תלויה בתקציב
שפיטות	קלה יותר	מורכבת, בגלל שיקולי תקציב
דוגמאות	ביטוי, חירות, דת	דיור, חינוך, בריאות, קצבאות

17.2 אין זכויות חברתיות מנויות; הפתרון: קיום מינימלי בכבוד

חוקי היסוד אינם מונים זכויות חברתיות. הפסיקה פתרה זאת בכך שהכירה ב**זכות לקיום מינימלי בכבוד** (או: "מינימום של קיום אנושי") כנגזרת מכבוד האדם (פרק 9). הרעיון: אדם שחייו אינם מאפשרים מזון, מחסה, בריאות וצרכים בסיסיים אחרים אינו יכול לחיות בכבוד, ולכן המדינה חייבת להבטיח רף בסיסי. זו הכרה בליבה החברתית של הכבוד, ולא הכרה בכל זכות חברתית כזכות חוקתית. מעבר לרף זה, זכויות חברתיות הן זכויות שבחוק או שבמדיניות, ומוגנות בחקיקה רגילה ובכללי המנהל.

✦ הגדרה — קיום מינימלי בכבוד

זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם, המחייבת את המדינה להבטיח לכל אדם תנאי קיום בסיסיים. היא אינה זכות לרמת חיים מסוימת אלא לרף מינימלי ("ליבה").

⚖ פסק דין — עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ׳ שר האוצר (בג"ץ 366/03, 2005)

נדונו קיצוצים בקצבאות הבטחת הכנסה ובתשלומים נוספים, שעל פי העתירה פגעו בזכותם של אנשים לקיום מינימלי. בית המשפט הכיר בעיקרון: הזכות לקיום מינימלי בכבוד היא זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם, והמדינה חייבת להבטיח רף בסיסי. עם זאת, נקט ריסון בקביעת מדיניות כלכלית, ודחה את העתירה, מאחר שלא הוכח שהקיצוצים, במכלול הסדרי הרווחה, פגעו בליבת הזכות. ההלכה: הכרה עקרונית וריסון בהקצאת משאבים.

⚖ פסק דין — חסן נ׳ המוסד לביטוח לאומי (בג"ץ 10662/04, 2012)

הסדר בחוק הבטחת הכנסה שלל קצבה ממי שיש ברשותו או בשימושו רכב, בלי אפשרות לסתור את החזקה גם כשהרכב נחוץ. בהרכב מורחב נקבע שחזקה חלוטה וגורפת, השוללת קצבת קיום בסיסית, פוגעת בזכות לקיום מינימלי בכבוד באופן בלתי מידתי, ונקבע שבעלות או שימוש ברכב אינם עילה אוטומטית לשלילת הזכאות. ההלכה: יישום מעשי של הזכות לקיום מינימלי; הפגיעה נבחנת בפסקת ההגבלה.

17.3 זכויות חברתיות בחקיקה רגילה

- **חינוך** - חוק לימוד חובה (1949) וחוק חינוך מיוחד (1988).
- **בריאות** - חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1994): זכות לשירותי בריאות בסל.
- **ביטחון סוציאלי** - חוק הבטחת הכנסה (1980) וחוק הביטוח הלאומי.
- **דיור** - חקיקה ומדיניות, ללא זכות חוקתית לדיור.

כל הזכויות האלו הן זכויות שבחוק, ולכן הרשות המבצעת מחויבת למלא אותן, ובתי המשפט מפקחים באמצעות עילות מנהליות רגילות. הזכות החוקתית לקיום מינימלי יוצרת "רצפה" שמתחתיה אין להפחית, גם אם הכנסת תחליט אחרת, אלא אם ההפחתה עומדת בפסקת ההגבלה.

17.4 ריסון שיפוטי והפרדת רשויות

כשהשאלה היא תקציבית, בית המשפט נוקט ריסון. הוא מכיר בכך שהקצאת משאבים מוגבלים בין צרכים מתחרים היא בעיקרה עניין למחוקק ולממשלה. לכן העיקרון שנקבע: בית המשפט יתערב בעיקר כשנפגעת ליבת הזכות (קיום מינימלי) או כשההסדר גורף, שרירותי או בלתי מידתי. הוא אינו קובע בעצמו את גובה הקצבה או את סדר העדיפויות התקציבי. הביקורת על הגישה היא שהיא מותירה את המצוקה החברתית בלי הגנה מספקת.

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לטעון שיש זכות חוקתית לדיור או לחינוך - אין, אלא בחקיקה.
- לטעון שהזכות לקיום מינימלי מבטיחה רמת חיים גבוהה - היא ליבה בלבד.
- לטעון שבעמותת מחויבות לשלום נפסל הסדר הקצבאות - העתירה נדחתה.
- לטעון שחסן נדחתה - נקבע שהחזקה הגורפת בעניין רכב אינה מידתית.

17.5 שלד לפתרון שאלה

1. מהי הזכות החברתית? האם היא מנויה או נגזרת?
2. האם נפגעה ליבת הקיום המינימלי בכבוד?
3. אם כן - החל את פסקת ההגבלה: חוק, ערכים, תכלית ראויה, מידתיות.

4. אם הפגיעה היא ברובד העליון של זכות חברתית - בחן בחקיקה רגילה ובכללי המנהל.
5. התחשב בריסון השיפוטי בעניינים תקציביים.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק קובע שמי שמחזיק רכב לא יקבל קצבת הבטחת הכנסה, ללא אפשרות לטעון שהרכב נחוץ לנכה. **פתרון:** החוק פוגע בזכות לקיום מינימלי; החזקה החלוטה גורפת ואינה מאפשרת הבחנה פרטנית; הפגיעה אינה מידתית (חסן). סעד: פסילת ההוראה או הוספת אפשרות לסתור.

17.6 הקשר למשפט הבינלאומי ולמדיניות

ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות העוסקות בזכויות חברתיות, כמו האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. אמנות אלה אינן חלק ישיר מהדין הפנימי, אך משמשות מקור פרשני והשראה. בית המשפט נוטה להשתמש בהן לביסוס עקרונות כמו קיום בכבוד. בנוסף, הביקורת על המדיניות החברתית מתנהלת גם באמצעות כלים מנהליים, כגון עילת הסבירות והחובה לשקול שיקולים רלוונטיים, ולא רק בכלים חוקתיים.

17.7 שלושה רבדים של הגנה על צרכים חברתיים

רובד	מקור ההגנה	תפקיד בית המשפט
ליבת הקיום המינימלי	זכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם	ביקורת חוקתית לפי פסקת ההגבלה
זכויות שבחוק (חינוך, בריאות, ביטחון סוציאלי)	חקיקה רגילה	ביקורת מנהלית על ביצוע החוק
רמות שירות גבוהות מהליבה	מדיניות ותקציב	ריסון שיפוטי, וההכרעה בידי המחוקק והממשלה

	עמותת מחויבות (2005)	חסן (2012)
מה נתקף	קיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה ובתשלומים נוספים	הוראה השוללת קצבה ממי שיש לו רכב
התוצאה	הזכות הוכרה והעתירה נדחתה	ההסדר הגורף נפסל, בחלקו
מה ללמוד	ריסון בעניינים תקציביים	חזקה חלוטה וגורפת אינה מידתית

! שים לב — מלכודות נוספות

- לבלבל בין הזכות החוקתית לקיום מינימלי לבין זכויות שבחוק: הן שונות בעוצמה ובסוג הביקורת.
- לטעון שריסון שיפוטי פירושו שהזכות אינה קיימת - הזכות הוכרה, והריסון נוגע להיקף ההתערבות.

✎ דוגמה — תרגיל פתור נוסף

משרד ממשלתי קיצץ באופן כללי קצבה לקשישים, והעותר טוען לפגיעה בזכות לקיום מינימלי. **פתרון:** יש לבדוק אם הקיצוץ פוגע בליבת הקיום המינימלי של הנפגעים. קיצוץ שמותיר אותם מעל הרף הוא עניין של מדיניות ותקציב, ובית המשפט ינהג ריסון, כמו בעמותת מחויבות. קיצוץ גורף ששולל קיום בסיסי בלי הבחנה פרטנית עלול להיפסל כבלתי מידתי, כמו בחסן.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- אין זכויות חברתיות מנויות.
- הזכות לקיום מינימלי בכבוד נגזרת מכבוד.
- עמותת מחויבות (2005): הכרה וריסון; חסן (2012): חזקה גורפת בעניין רכב נמצאה בלתי מידתית.
- ריסון שיפוטי בעניינים תקציביים.

פרק 18

מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

18.1 הגדרת המדינה: יהודית ודמוקרטית

ישראל מוגדרת בחוקיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הביטוי מופיע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (ס׳ 1א ובפסקת ההגבלה, שדורשת התאמה לערכיה של מדינת ישראל), בחוק יסוד: חופש העיסוק, בחוק יסוד: הכנסת (ס׳ 7א) ובחוק יסוד: הלאום (2018). מגילת העצמאות היא מקור היסוד לשני המרכיבים: הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וכן שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל תושביה בלי הבדל דת, גזע ומין. השאלה המשפטית המרכזית היא כיצד ליישב בין שני המרכיבים כשהם מתנגשים.

✦ הגדרה — הסינתזה של הנשיא ברק

אין להעדיף מרכיב אחד על האחר. יש לפרש כל אחד מהם ברמת הפשטה גבוהה: "יהודית" כוללת ערכים אוניברסליים של המורשת היהודית (כגון צדק, שוויון, כבוד האדם) ומאפיינים לאומיים (שפה, חגים, עלייה). "דמוקרטית" כוללת ריבונות העם, זכויות אדם, הפרדת רשויות ושלטון החוק. בהתנגשות יש לחפש הרמוניה, ורק כשאין ברירה לאזן.

18.2 מאפייני "מדינה יהודית" ו"מדינה דמוקרטית"

יהודית	דמוקרטית
רוב יהודי ואפשרות לעלייה (חוק השבות)	ריבונות העם ובחירות
שפה עברית, חגים ושבת	זכויות אדם ושוויון
מורשת ישראל ותרבותה	הפרדת רשויות
ערכי המורשת היהודית (צדק, כבוד)	שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית

הלכת טיבי, שעסקה בפסילת מפלגות (פרק 10), נשענת על ההגדרות האלו, ומציגה את מאפייני המדינה היהודית והדמוקרטית כמסגרת לפרשנות. קעדאן (פרק 13) מדגימה שהיהדות של המדינה אינה מתירה אפליה בהקצאת משאבי ציבור.

18.3 חוק השבות והגדרת "יהודי"

חוק השבות, התש"י-1950, מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות ארצה. חוק האזרחות (1952) מסדיר את ההגירה לאזרחות. בתיקון משנת 1970 הוגדר "יהודי" בחוק השבות: מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר, ושאינו בן דת אחרת. התיקון הרחיב את הזכות גם לילד, לנכד ולבן זוג של יהודי. המשמעות היא שיש הבחנה מותרת בהגירה ובמעמד, נגזרת מאופייה היהודי של המדינה, בעוד שבהקצאת משאבים לאזרחים חל שוויון.

⚖ פסק דין — רופאייזן נ׳ שר הפנים - "האח דניאל" (בג"ץ 72/62, 1962)

אוסוולד רופאייזן נולד יהודי, ניצל בשואה והמיר את דתו לנצרות ונעשה נזיר, ולאחר מכן ביקש לעלות לישראל מכוח חוק השבות. בית המשפט, ברוב, דחה את העתירה. נקבע שיש לפרש את המונח "יהודי" בחוק לפי משמעותו המקובלת בציבור, כלומר בהקשר האזרחי-חילוני, ולא רק לפי ההלכה. לפי משמעות זו, מי שהמיר את דתו מרצון ונעשה בן דת אחרת אינו נחשב יהודי לצורך חוק השבות. ההלכה: המבחן הוא ה"יהודי" כפי שמבינים אותו אנשי העם היהודי.

⚖ פסק דין — שליט נ׳ שר הפנים (בג"ץ 58/68, 1970)

אב יהודי ואם שאינה יהודייה ביקשו לרשום את ילדיהם כ"יהודים" בלאום ובלי דת. נדונה סמכות פקיד המרשם לבחון את הצהרות ההורים בשאלות של זהות ולאום, וההבחנה בין רישום טכני לשאלה המהותית. בית המשפט, ברוב דחוק, הורה לרשום בהתאם להצהרה בתום לב. בעקבות הפסק תוקן חוק השבות בשנת 1970 והוגדר "יהודי". ההלכה: הצורך בהסדרה חקיקתית של שאלות זהות.

18.4 חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (2018)

חוק יסוד: הלאום עיגן את זהותה היהודית של המדינה ברמה חוקתית. הוא קובע, בין היתר, שארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שהזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינה ייחודית לעם היהודי, שירושלים בירת ישראל, שהעברית היא שפת המדינה ולערבית מעמד מיוחד, ושהמדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי. החוק נגדו הוגשו עתירות בטענה לפגיעה בשוויון ובאופי הדמוקרטי של המדינה.

⚖ פסק דין — חסון נ׳ הכנסת - חוק הלאום (בג"ץ 5555/18, 2021)

בהרכב מורחב של אחד-עשר שופטים נדחו העתירות נגד חוק יסוד: הלאום, ברוב גדול. נקבע שהחוק אינו שולל את אופייה הדמוקרטי של המדינה, שהוא נקרא יחד עם יתר חוקי היסוד ועם ערך השוויון, ושאין בו כדי לגרוע מזכויות הפרט. בית המשפט לא פסל את החוק וגם לא הכריע סופית בשאלת הסמכות לבקר חוקי יסוד באופן כללי. הרוב היה 10 מול 1.

18.5 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות

- לטעון שהמדינה "יהודית" פירושו אפליה בהקצאת משאבים - לפי קעדאן לא.
- לבלבל בין חוק השבות (הגירה) לבין שוויון האזרחים.
- לטעון שרופאייזן הוכרע על פי ההלכה - נקבע לפי משמעות אזרחית-חילונית.
- לטעון שחוק הלאום נפסל - העתירות נדחו.

18.6 שלד לפתרון שאלה

1. מהו הנושא: הגירה ומעמד, או הקצאת משאבים וזכויות אזרחים?
2. האם יש הבחנה? אם כן, האם היא נגזרת מאופי המדינה?
3. החל סינתזה ברמות הפשטה: מצא הרמוניה בין היהודי לדמוקרטי.
4. בדוק פסקת ההגבלה ושוויון.
5. נמק לפי הפסיקה: קעדאן, רופאייזן, שליט, חסון.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

יישוב מקבל מועמדים רק ממי ששירת בצבא, ובפועל חוסם ערבים. **פתרון:** הקצאת משאב ציבורי (קרקע) חייבת בשוויון, והיהדות של המדינה אינה מצדיקה אפליה (קעדאן). קריטריון נייטרלי לכאורה בעל תוצאה מפלה נדרש להצדקה עניינית ומידתית; בהיעדרה הוא פסול.

18.7 נקודות למבחן ושאלות נפוצות

בשאלות על "מדינה יהודית ודמוקרטית" הטעות הנפוצה היא להציג את שני המרכיבים כמתנגשים תמיד. בפועל, ברוב המקרים אין התנגשות: עלייה חופשית וסמלים לאומיים אינם פוגעים בשוויון האזרחים.

ההתנגשות מתעוררת בהקצאת משאבים, בקבלה ליישובים ובחוקי יסוד המדגישים את הזהות היהודית. בכל מקרה יש לבדוק את ההקשר, לציין את הערך הנפגע, ולהסביר מדוע התוצאה שומרת על האיזון. כמו כן, יש לזכור שהכרעת הפסיקה בשאלת "מיהו יהודי" נעשתה בפרשנות החוק ולא בהכרעה הלכתית.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- "יהודית ודמוקרטית": סינתזה ברמות הפשטה (ברק).
- חוק השבות: הבחנה מותרת בהגירה; הגדרת יהודי (1970).
- רופאייזן: משמעות אזרחית-חילונית; שליט: הסדרה חקיקתית.
- חוק הלאום 2018; חסון 2021: העתירות נדחו.

פרק 19

חופש העיסוק

19.1 חוק היסוד ותכליתו

חוק יסוד: חופש העיסוק נחקק ב-1992, ונחקק מחדש בשנת 1994 עם תוספת מרכזית: פסקת התגברות (ס׳ 8). זהו אחד משני חוקי היסוד של "המהפכה החוקתית". הוא עוגן במטרה להגן על חופש העיסוק כדי לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בשונה מחוק יסוד: כבוד האדם, חופש העיסוק הוא זכות מנויה ומפורשת, ולכן שאלת הגדרתה אינה דורשת גזירה מכבוד.

§ סעיף — ס׳ 3 ו-4 לחוק יסוד: חופש העיסוק

ס׳ 3: "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד."

ס׳ 4: "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

19.2 היקף הזכות

הזכות מגינה על החופש לבחור עיסוק, מקצוע או משלח יד, להיכנס אליו, לעסוק בו, ולצאת ממנו. היא חלה על אזרחים ותושבים. היא אינה מבטיחה הצלחה כלכלית או רווח, ואינה מגנה על הקניין בעסק (שהוא חלק מזכות הקניין בחוק כבוד האדם). הפגיעה בחופש העיסוק יכולה להיות ישירה (איסור לעסוק במקצוע) או עקיפה (תנאים כבדים, רישוי, מכסות). בחינת הפגיעה עוסקת בעוצמתה: הסדרה רגילה של מקצוע, כגון דרישות הכשרה, היא פגיעה שנבחנת בפסקת ההגבלה, אך הסבירות להצדקתה גבוהה כשהיא נועדה להגן על הציבור.

סוג הפגיעה	דוגמה	עוצמה

איסור על עיסוק	איסור יבוא מוצר מסוים	גבוהה
תנאי כניסה אישיים	דרישת השכלה או רישיון מקצועי	בינונית; הצדקה בהגנת הציבור
תנאי כניסה אובייקטיביים	מכסות או מספר מוגבל של רישיונות	גבוהה
הסדרת אופן העיסוק	שעות פעילות, בטיחות	נמוכה יחסית

19.3 פסקת ההגבלה בחופש העיסוק

הבחינה נעשית לפי ארבעת התנאים (פרק 4): בחוק או לפי הסמכה מפורשת, הולם ערכי המדינה, תכלית ראויה, ומידתיות. תכליות ראויות אופייניות: הגנה על בריאות הציבור, בטיחות, הגנת הצרכן ויושרה מקצועית. בנושא המידתיות, חשוב לבחון אם יש אמצעי פוגע פחות, ובעיקר **הסדרי מעבר** לעוסקים ותיקים, שהמקצוע היה מקור פרנסתם לפני החוק החדש.

⚖ פסק דין — מיטראל נ׳ ראש הממשלה ושר הדתות (בג"ץ 3872/93)

חברה ביקשה לייבא בשר שאינו כשר, והרשויות סירבו מכוח מדיניות שהתבססה על שיקולי כשרות. בית המשפט קבע שהמדיניות פוגעת בחופש העיסוק ללא בסיס חקיקתי מפורש ואינה עומדת בפסקת ההגבלה, והיא נפסלה. בעקבות הפסיקה הכניסה הכנסת פסקת התגברות לחוק היסוד, וחוקקה מכוחה את חוק יבוא בשר. ההלכה: פגיעה בחופש העיסוק מחייבת בסיס חקיקתי מפורש, והפרשה היא רקע לפסקת ההתגברות.

⚖ פסק דין — לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ׳ שר האוצר (בג"ץ 1715/97, 1997)

חוק חדש הסדיר את מקצוע ניהול תיקי השקעות והטיל דרישות רישוי. נדונה פסקת ההגבלה בחוק היסוד, ובפרט עקרונות תכלית ראויה ומידתיות. נקבע שהסדרת המקצוע והגנה על ציבור המשקיעים הן תכלית ראויה, אך יש לבחון בקפידה את מידתיות הדרישות, ובפרט את פגיעתן בעוסקים ותיקים וצורך בהסדרי מעבר. ההלכה: הסדרת מקצוע לשם הגנת הציבור תותר, בכפוף למידתיות; הלכה מנחה ליישום הפסקה בחופש העיסוק. הוראת המעבר שדרשה בחינות ממי שניסיונו קצר משבע שנים נפסלה כפגיעה בלתי מידתית.

19.4 פסקת ההתגברות בחופש העיסוק

ס׳ 8 מאפשר לכנסת לחוקק חוק הפוגע בחופש העיסוק גם כשהוא אינו עומד בפסקת ההגבלה, בתנאי שהחוק התקבל ברוב חברי הכנסת, נאמר בו במפורש שהוא תקף "על אף האמור בחוק יסוד זה", ותוקפו פוקע בתום ארבע שנים. הדוגמה היא חוק יבוא בשר. נושא זה נדון בהרחבה בפרק 5, והוא מדגיש שחופש העיסוק הוא הזכות החוקתית היחידה שמוגנת בפני פסילה בדרך של התגברות.

★ טיפ למבחן — טיפ למבחן

בשאלה על חופש העיסוק: (1) האם הנפגע אזרח או תושב? (2) האם הפגיעה בחופש העיסוק, או בקניין בלבד? (3) האם יש חוק או הסמכה מפורשת? (4) תכלית ראויה ומידתיות, כולל הסדרי מעבר; (5) האם חל ס׳ 8 וההתגברות?

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לבלבל בין חופש העיסוק לקניין (האחרון בחוק כבוד האדם).
- להתעלם מהצורך בבסיס חקיקתי מפורש.
- לטעון שחופש העיסוק מבטיח רווח.
- לשכוח שהפסקה החוקית היא ס׳ 4 ושההתגברות ס׳ 8.

19.5 שלד לפתרון שאלה

1. מהי הפגיעה: ישירה או עקיפה? מהי עוצמתה?
2. האם יש חוק או הסמכה מפורשת?
3. האם הוא הולם את ערכי המדינה, ולתכלית ראויה?
4. האם הוא מידתי: התאמה, אמצעי פוגע פחות, מידתיות במובן הצר (כולל הסדרי מעבר)?
5. האם נחקק בפסקת התגברות? בדוק אמירה, רוב ותוקף.

✎ דוגמה — תרגיל פתור

חוק חדש מחייב רישיון לייעוץ פיננסי, וקובע שמי שעסק במקצוע ותיק נדרש לעבור מבחן חדש תוך חודש או לפרוש. **פתרון:** פגיעה בחופש העיסוק; התכלית (הגנת צרכנים) ראויה; הרישוי מתאים. אך חוסר הסדרי מעבר לוותיקים עלול להיות בלתי מידתי, כי קיימת חלופה פוגעת פחות, כגון הסדר מעבר או פטור לוותיקים.

19.6 חופש העיסוק במבט כלכלי

חופש העיסוק משמש גם כלי להגנה על תחרות. חוקים המגבילים כניסה לענף, כמו מכסות, רישוי רחב או מונופול, נתפסים כפגיעה בחופש העיסוק, ולכן נבחנים בפסקת ההגבלה. הכנסת נהנית ממרווח שיקול

דעת רחב בנושאים כלכליים, ולכן בית המשפט ינקוט ריסון, אך יידרש לבסיס עובדתי למידתיות הפגיעה. בנוסף, נבחנת השאלה אם הרגולציה נועדה להגן על הציבור או על ציבור העוסקים הקיימים (הגנת קרטל), שאינה תכלית ראויה.

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- ס׳ 3: חופש העיסוק לאזרחים ותושבים; ס׳ 4: פסקת הגבלה; ס׳ 8: התגברות.
- הזכות אינה מבטיחה רווח ואינה קניין.
- מיטראל: צורך בבסיס חקיקתי מפורש; נולדה פסקת ההתגברות.
- לשכת מנהלי ההשקעות: תכלית ראויה ומידתיות; הסדרי מעבר.